

제5장 민사집행에서의 불복방법

제1절 집행절차에서의 불복방법 개요

1. 민사집행법상의 불복방법 체계

민사소송법과 민사집행법은 집행권원을 형성하는 절차인 좁은 의미의 소송절차와 그 집행권원의 내용을 강제적으로 실현하는 집행절차를 구분하여 원칙적으로 소송절차에 관련된 불복절차는 소송절차 내에서, 집행절차에 관련된 불복절차는 집행절차 내에서 처리 되도록 하고 있다.

대표적 집행권원인 판결의 형성절차와 관련하여 보면 판결확정 전에도 가집행의 선고가 붙은 판결에 기하여 강제집행절차가 개시될 수 있지만, 그 가집행의 선고가 붙은 판결의 실제적 권리에 관한 다툼은 소송절차인 상소제도에서 처리된다. 또한, 판결확정 후에 그 실제적 권리를 다투는 재심절차도 소송절차 내에서 처리되고, 상소절차와 재심절차는 민사소송법이 정하고 있다.

집행권원 형성기관과 집행기관 사이를 연결하는 제도가 집행문제인데, 집행문부여는 강제집행절차가 개시되기 전의 절차로서 수소법원의 법원사무관등이 담당하는 것이지만 집행권원이 형성된 후의 절차이고, 실제상의 권리 또는 법률관계의 존부를 확정하는 것이라기보다는 이미 판결절차에서 확정된 법률관계를 강제적으로 실현시키는 것을 허용할 것인지 여부를 판단하는 단계에 속하는 것이므로, 민사집행법이 이를 규정하고 있다. 민사집행법은 집행문과 관련한 불복절차로 집행문부여 등에 관한 이의신청(민집 34조), 집행문부여의 소(민집 33조), 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 45조) 제도를 두고 있다.

민사집행법은 변론이 종결된 뒤에 생긴 이유에 의하여 확정판결의 집행력을 배제시키는 청구이의의 소(민집 44조) 제도를 두고 있는데, 청구이의는 집행권원인 확정판결상 실제

적 권리에 관한 다툼이므로 민사집행법은 이 다툼을 집행절차 밖에서 별개의 소송절차로 처리되도록 하는 한편 다툼의 대상이 된 판결의 제1심 판결법원이 관할하도록 하고 있다(민집 44조 1항).

이와 달리 제3자가 강제집행의 목적물에 대한 권리를 주장하여 그 목적물에 대한 채권자의 강제집행을 저지하는 제3자이의의 소(민집 48조)는 집행절차에서의 다툼을 대상으로 하는 것이지만 집행목적물에 대한 실체적 권리에 관한 다툼을 내용으로 하는 것이므로, 민사집행법은 이 다툼을 당해 집행절차 밖에서 별개의 소송절차로 처리되도록 하되 집행법원(또는 집행법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원의 합의부)이 관할하는 것으로 정하고 있다(민집 48조 2항). 이와 같은 유형에 속하는 것으로 배당이의의 소가 있는데 그 내용이 되는 다툼 역시 집행절차 중 배당단계에서의 다툼이지만 배당채권의 존부 및 그 순위와 관련된 실체적 권리에 관한 다툼이므로, 민사집행법은 당해 집행절차 밖에서 별개의 소송절차로 처리되도록 하되 배당을 실시한 집행법원이 속한 지방법원(또는 그 지방법원의 합의부)의 관할로 하고 있다(민집 156조).

한편 민사집행법은 집행절차 내에서 집행기관의 집행처분에 위법이 있을 경우에는 이해관계인의 즉시항고(민집 15조) 또는 집행에 관한 이의신청(민집 16조)으로 집행절차 내에서 처리되도록 하고 있다. 즉시항고와 집행에 관한 이의신청은 불복대상인 집행처분의 효과와 그 중요성에 착안하여 불복방법에 차이를 둔 것이라고 할 수 있는데, 민사집행법은 집행절차에 관한 집행법원의 재판 중 항고법원에 의한 판단이 필요한 것에 대하여는 특별히 즉시항고를 할 수 있다는 규정을 두어 항고법원에 의하여 불복이 심리·판단되도록 하고 재항고를 허용하는 반면, 집행법원의 집행절차에 관한 그 밖의 재판과 집행관의 집행처분이나 집행관이 지킬 집행절차에 대하여는 이해관계인이 집행에 관한 이의를 신청하도록 하여 집행법원이 심리·판단하고 집행법원의 집행이의 재판에 대하여는 원칙적으로 다시

75 불복할 수 없도록 하고 있다. 즉시항고는 1주 이내에 제기하여야 하고 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 하는 데에 반하여, 집행에 관한 이의신청의 경우에는 이러한 제한이 없다. 민사소송법과 민사집행법이 집행권원 형성절차인 판결절차와 집행권원상의 권리를 강제적으로 실현하는 집행절차를 구분하고 있는 결과로 집행 단계의 불복절차인 즉시항고와 집행에 관한 이의신청에서는 원칙적으로 집행권원상의 실체적 권리에 관한 다툼을 불복이유로 할 수 없고 집행절차상의 위법만을 불복이유로 할 수 있지만, 집행권원에 기초하지 않는 담보권의 실행절차에 있어서는 그 분리가 엄격하지 않고 담보권의 부존재, 소멸 등 실체상의 다툼에 대한 판단을 집행절차에서 하지 않을 수 없으므로 이러한 사유도 불복

의 이유가 된다(민집 265조 참조).

이상의 내용에 따라 민사집행법이 정하고 있는 불복절차를 정리해 보면 다음과 같다.

① 집행권원상의 실체적 권리에 관한 다툼을 내용으로 하는 불복절차로 청구이의의 소가 있으며, 원칙적으로 제1심 판결법원이 관할한다(민집 44조 1항).

② 집행개시 전인 집행문부여 단계에서의 불복절차로 집행문부여 등에 관한 이의신청(민집 34조), 집행문부여의 소(민집 33조), 집행문부여에 대한 이의의 소(민집 45조)가 있으며, 원칙적으로 제1심 수소법원이 관할한다.

③ 집행절차 단계에서의 불복절차이지만 불복의 내용이 되는 다툼이 실체적 권리에 관한 것이어서 소송절차로 처리되는 것으로는 제3자의이의 소(민집 48조)와 배당이의의 소(민집 156조)가 있으며, 집행법원이나 집행법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원의 합의부 등이 관할한다.

④ 집행절차 단계에서의 불복절차로서 즉시항고(민집 15조)와 집행에 관한 이의신청(민집 16조)이 있으며, 각각 집행법원의 항고법원과 집행법원이 관할한다.

한편 사법보좌관이 즉시항고의 대상이 되는 처분을 한 경우에는 사법보좌관규칙 4조에 따라 이의신청을 할 수 있고, 사법보좌관이 집행이의의 대상이 되는 처분을 하거나 배당표를 작성한 경우에는 사법보좌관규칙 3조 2호, 4호에 따라 불복할 수 있다.

2. 민사소송법상 불복방법과의 관계

76

제1편
제5장
제1절

가. 통상항고와 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청의 준용 여부

(1) 민사소송법 439조(구 민사소송법 409조)는 소송절차에 관한 신청을 기각한 결정이나 명령에 대하여 불복하면 항고할 수 있다고 규정하고 있고, 민사소송법 223조(구 민사소송법 209조)는 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청제도를 규정하고 있다. 소송법과 집행법이 분리되지 않은 구 민사소송법 하에서는 강제집행면에 특별한 규정이 없는 경우 위와 같은 통상항고와 이의신청에 의한 불복을 허용하는 것으로 해석하는 견해가 있었다. 현재 민사소송법과 민사집행법이 분리되어 있지만 민사집행법 23조가 민사집행법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민사집행 및 보전처분의 절차에 관하여는 민사소송법의 규정을 준용한다는 포괄적 준용규정을 두고 있기 때문에 민사집행법하에서도 위와 같은 해석론이 계속될 여지가 있다.

(2) 구 민사소송법 당시 위 규정의 적용이 문제된 것 중 중요한 것을 검토해 보면 다음과 같다.

① 법원사무관등이 집행문부여를 거절한 처분에 대하여 구 민사소송법이 집행문부여의 소에 의한 불복절차 외에 이의신청에 관하여는 아무런 규정을 두지 않았기 때문에 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청이 허용된다는 것이 통설이었다. 그러나 민사집행법 34조 1항은 집행문부여를 거절한 법원사무관등의 처분에 대한 이의신청절차를 규정하고 있기 때문에 이와 관련하여서는 민사소송법 223조가 준용될 여지가 없게 되었다.

② 구 민사소송법상 집행문부여에 대한 이의신청에 관한 재판에 대한 불복방법으로 집행이의설과 통상항고설이 주장되기도 하였다. 그러나 판례는 그 재판에 대하여는 일반 소송절차에 관한 구 민사소송법 409조의 통상항고 규정에 따를 수 없고 같은 법 504조의 집행에 관한 이의도 할 수 없으며 같은 법 517조의 즉시항고도 할 수 없어 결국 불복절차가 없기 때문에 같은 법 420조의 특별항고만 허용될 뿐이라고 하여 불복불가설(특별항고설)을 채택하였다(대결 1995. 5. 13. 94마2132, 대결 1997. 6. 20. 97마250). 따라서 민사집행법의 77 해석으로도 이와 관련하여 민사소송법 439조가 준용될 여지는 없다고 할 것이다.

③ 구 민사소송법은 채무불이행자명부 등재말소신청을 기각한 결정에 대하여 아무런 불복방법을 정하지 않았는데, 구 민사소송법의 해석으로는 채무불이행자명부 등재절차가 강제집행절차가 아니므로 채무자가 집행에 관한 이의신청을 할 여지는 없고 통상항고에 의하여 불복할 수 있다는 견해가 통설이었다. 민사집행법 역시 채무불이행자명부 등재말소신청을 인용한 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다는 규정(민집 73조 2항 전문)을 두면서도 그 신청을 기각한 결정에 대한 불복방법에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로 통상항고에 관한 민사소송법의 규정을 준용하여야 한다는 해석론이 있을 수 있다. 그러나 민사집행법 15조 1항과 16조 1항의 '집행절차'를 협의의 강제집행절차로 한정하여 해석할 수 없고, 민사집행법이 개개의 절차에서 즉시항고의 허용 여부를 규정하고 있는 점에 비추어 보면 민사집행절차에서 통상항고에 관한 민사소송법의 규정을 준용하는 것은 제한적이어야 하므로, 채무불이행자명부 등재말소신청을 기각한 결정에 대하여 민사소송법상의 통상항고로 불복할 수는 없고 집행에 관한 이의신청만을 할 수 있다고 할 것이다.

④ 구 민사소송법은 가압류신청을 기각한 결정에 대한 불복방법을 따로 규정하지 않았기 때문에 이러한 결정에 대하여 통상항고를 제기할 수 있다는 것이 통설이었고, 무담보의 가압류결정을 구하는 신청에 대하여 법원이 일정한 액수의 담보를 제공하는 것을 조건으로 가압류를 명하는 경우 이는 실질적으로 가압류신청에 대한 일부 기각의 재판과 같은 성격을 가지는 것이므로 신청인으로서 위 일부 기각 부분(담보를 조건으로 명한 부분)에 대하여 통상의 항고로써 다룰 수 있다는 것이 판례였다(대결 2000. 8. 28. 99그30). 그러

나 민사집행법 281조 2항은 가압류신청을 기각하거나 각하하는 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다고 규정하고 있으므로 이와 관련하여 민사소송법상의 통상항고에 관한 규정이 준용될 여지는 없다.

(3) 이상에서 든 것 외에도 민사집행법은 구 민사소송법 당시 논의되었던 불복절차에 관한 문제 대부분을 입법으로 해결하는 한편 민사집행법 전반에 걸쳐서 각 제도와 관련된 불복절차를 세심하게 규정하고 있다. 따라서 민사집행법에서 특별히 불복을 허용하는 규정을 두고 있지 않고 집행에 관한 이의신청의 요건에도 해당하지 않는 경우에는 불복이 허용되지 않는다고 해석하는 것이 원칙일 것이고, 쉽게 민사집행법 23조에 의하여 민사소송법상의 통상항고 규정이 준용된다고 하여서는 아니 될 것이다.

78

한편 판례는 경매목적 부동산이 매각되어 그 매각대금이 모두 지급되었음에도 법원사무관등이 그에 따른 후속 조치로서의 등기촉탁을 거절하는 경우 민사소송법 223조를 준용하여 매수인은 법원사무관등의 처분에 대한 이의를 제기할 수 있고, 그 이의를 기각한 결정에 대하여는 민사소송법 439조를 준용하여 통상항고에 의하여 불복할 수 있으나(대결 2009. 10. 16. 2009그90), 그 이의를 인용한 결정에 대하여는 민사소송법 439조를 준용할 수 없으므로 통상항고를 할 수 없고 민사소송법 449조를 준용하여 특별항고로써 불복할 수 있다고 한다(대결 2013. 5. 6. 2013마325).

나. 재항고와 특별항고의 준용

즉시항고에 대한 항고법원의 재판에 대하여는 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반을 이유로 들어 재항고를 할 수 있고(민소 442조 준용), 불복할 수 없는 집행법원의 재판에 대하여는 재판에 영향을 미친 헌법위반이 있거나, 재판의 전제가 된 명령·규칙·처분의 헌법 또는 법률의 위반 여부에 대한 판단이 부당하다는 것을 이유로 하는 때에만 대법원에 특별항고를 할 수 있다(민소 449조 준용).

제1편
제5장
제1절

3. 사법보좌관제도의 도입과 불복방법의 변형

가. 총설

민사소송법과 민사집행법은 사법보좌관제도 도입 이전에 입법된 것이므로, 당연히 판사가 소송·집행 절차상의 업무를 수행하는 것을 전제로 하여 판사가 한 재판 등 처분에 대한 불복방법을 정하고 있다. 반면 사법보좌관은 위와 같은 입법 후에 시행된 법원조직법 54

79

조와 사법보좌관규칙 2조에 의하여 판사 대신 소송·집행 절차상의 업무를 수행하게 되었으므로, 사법보좌관이 한 재판 등 처분에 대한 불복은 법원조직법 54조 3항과 사법보좌관규칙 3조, 4조에 따라 처리된다.

법원조직법 54조 3항은 “사법보좌관의 처분에 대해서는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 법관에게 이의신청을 할 수 있다.”라는 일반원칙을 선언하고 있다. 이것은 원래 사법보좌관의 업무를 판사가 처리하던 상황에서는 존재하지 않던 ‘이의신청’ 제도를 새로이 설정한 것이다. 즉, 판사의 처분에 대하여는 민사소송법이나 민사집행법에 따른 통상의 불복절차에 따르면 그만이지만, 사법보좌관의 처분에 대하여는 그 이전의 단계에서 ‘법관에게 이의신청’을 할 수 있도록 하였다. 이에 따라 민사소송법과 민사집행법 등 절차법의 규정은 그 한도에서 변형되는 결과에 이르게 되었다.

사법보좌관은 법관이 아니므로 사법보좌관의 처분에 대하여 법관이 심사할 수 있도록 함으로써 헌법 27조 1항의 “모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.”라는 규정과 헌법 101조 1항의 “사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.”라는 규정에 사법보좌관제도를 합치시키려는 조치이다. 그리하여 사법보좌관의 처분이라는 재판과 이에 대한 이의신청에 관한 판사의 재판이 하나의 심급에서 이루어짐으로써 사실상 제1심이 사법보좌관의 제1-1심과 판사의 제1-2심으로 나누어지게 되었다.

나. 두 가지의 불복유형 등

(1) 법원조직법 54조 3항의 위임에 따라 사법보좌관규칙은 3조에서 “지급명령 등의 처분에 대한 불복”을, 4조에서 “즉시항고 등의 대상이 되는 처분에 대한 이의신청”을 순차로 규정함으로써 다음과 같은 두 가지의 유형을 설정하고 있다.

- 80 ① 제1유형(규칙 3조) : 개별 법률에서 해당 처분에 대한 불복방법이 이의신청이고 그 이의신청에 대하여 같은 심급의 판사가 심사하도록 규정하고 있는 경우에는 해당 법률에서 규정하는 이의신청 절차를 그대로 따르도록 하였다.

우선, 사법보좌관의 처분 중 그러한 처분을 판사가 하였다면 민사집행법 16조의 집행에 관한 이의신청의 대상이 되는 경우에 대한 불복방법은 제1유형에 속한다. 이러한 경우에 있어서 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청 절차는 해당 처분을 판사가 한 경우와 원칙적으로 같다. 이것은 개별 법률에서 인정하는 불복수단과 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청이라는 이중의 불복방법을 두어서 생길 수 있는 절차상의 지연과 혼란을 막기 위한 것이

다. 그리하여 규칙 3조는 4조와 달리 ‘이의신청’이라는 용어 대신 ‘불복’이라는 용어를 사용하였고, 엄밀한 의미에서 규칙 3조는 법원조직법 54조 3항이 예정하고 있는 별도의 ‘이의신청’에는 해당하지 않는다.

한편 사법보좌관이 작성한 배당표와 관련하여, 2017. 3. 31. 개정 전의 구 사법보좌관 규칙 5조는 이에 대한 이의신청이 있는 경우에 배당기일을 중지하고 이의신청사건을 지체 없이 소속법원의 판사에게 송부함으로써 판사로 하여금 배당표를 작성하여 배당기일을 실시하도록 하고 이에 대하여 다시 이의 및 배당이의소송 등으로 불복하도록 하였으나, 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 이의절차에 사법보좌관 및 판사가 중복하여 관여함으로써 발생하는 배당 이해관계인의 불편을 해소하고 신속한 절차 진행을 도모하기 위하여 2017. 3. 31. 개정된 사법보좌관규칙은 5조를 삭제하고 3조 4호를 신설하여 사법보좌관이 작성한 배당표에 대한 불복도 민사집행법 151조에 규정된 배당표에 대한 이의 절차를 그대로 따르도록 하였다.

② 제2유형(규칙 4조) : 사법보좌관의 처분 중 그러한 처분을 판사가 하였다면 항고, 즉시항고 또는 특별항고의 대상이 되는 경우, 이에 대한 불복은 ‘이의신청’의 방법에 의하도록 하였다. 사법보좌관의 처분 중 그러한 처분을 판사가 하였다면 민사집행법 15조의 즉시항고의 대상이 되는 경우에 대한 불복방법은 제2유형에 속한다. 이에 대하여는 일단

81

(2) 위와 같은 불복제도의 두 가지 유형에 포함되지 않는 것도 있다. 민사집행법 32조, 35조의 경우가 이에 해당한다. 재판장을 집행하는 데에 조건을 붙인 경우와 승계집행문을 부여하는 경우 및 여러 통의 집행문을 신청하거나 전에 내어준 집행문을 돌려주지 아니하고 다시 집행문을 신청한 경우에 법원사무관등이 집행문을 부여하려면 ‘재판장의 명령’이 있어야 하는데, 이러한 재판장의 명령도 역시 사법보좌관규칙 2조 1항 4호에 의하여 사법보좌관의 업무범위에 포함된다. 만약 사법보좌관이 재판장을 대신하여 집행문의 부여를 허가하는 명령을 하지 않는 경우 집행문부여의 권한을 가진 법원사무관등은 집행문부여를 거부할 수밖에 없고, 그 반대의 경우 집행문부여를 할 수밖에 없는데, 이 경우의 불복방법으로는 집행문부여 거절처분에 대한 이의신청, 집행문부여의 소(집행문부여 거절의 경우)

와 집행문부여에 대한 이의신청, 집행문부여에 대한 이의의 소(집행문부여의 경우)가 있을 뿐이다. 이 경우 ‘재판장의 명령’은 독립된 재판이 아니라 내부적 지시에 불과하여 그 명령의 불법, 부당은 위와 같은 불복방법으로 다룰 수 있을 뿐 이와 별도로 재판장의 명령에 대하여 항고 등으로 불복하는 것은 부적법하고(대결 1967. 10. 13. 67마530 참조), 이는 사법보좌관이 ‘재판장의 명령’을 수행한 처분에 대하여도 마찬가지이기 때문이다.

(3) ‘사법보좌관의 처분에 대한 이의신청’ 제도로 즉시항고(민집 15조)와 집행에 관한 이의신청(민집 16조)에 생긴 변형에 관하여는 아래 해당 항목에서 다시 서술한다.

제2절 즉시항고

1. 의의

민사집행법은 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 대한 불복방법으로 즉시항고를 인정하고 있다. 그러나 이 불복방법은 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 허용되고(민집 15조 1항), 그러한 규정이 없는 경우에는 즉시항고에 의한 불복은 할 수 없고 민사집행법 16조에 따라 집행에 관한 이의신청으로 다투어야 한다.

다만 즉시항고를 할 수 있다는 특별한 규정이 없는 경우에도 해석상 그와 동일하게 취급되어야 한다고 인정되는 때에는 즉시항고가 허용된다(대결 1995. 1. 20. 94마1961). 민사집행법 17조 1항이 준용되는 경우가 대표적이다.

2. 즉시항고를 할 수 있는 재판

민사집행법, 민사집행규칙에서 즉시항고가 허용되는 것은 다음과 같다.

- ① 항고이유서 부제출 등을 이유로 한 원심법원의 즉시항고 각하결정(민집 15조 8항)
- ② 집행절차를 취소하는 결정, 집행절차를 취소한 집행관의 처분에 대한 이의신청을 기각·각하하는 결정 또는 집행관에게 집행절차의 취소를 명하는 결정(민집 17조 1항)
- ③ 집행비용을 예납하지 않음으로 인한 강제집행신청 각하 또는 집행절차 취소결정(민집 18조 3항)
- ④ 재산명시신청을 기각하거나 각하하는 결정(민집 62조 8항)

- ⑤ 이의신청에 의한 명시명령 취소 또는 이의신청 기각결정(민집 63조 5항)
- ⑥ 명시선서 후에 하는 재산목록 정정의 허가에 관한 결정(민집 66조 2항)
- ⑦ 재산명시절차 중 채무자를 감치에 처하는 결정(민집 68조 4항)
- ⑧ 채무불이행자명부 등재신청에 관한 등재결정 또는 기각결정(민집 71조 3항) 83
- ⑨ 채무불이행자명부 등재말소신청에 의한 말소결정(민집 73조 2항)
- ⑩ 재산조회를 받고 허위자료를 제출하거나 자료제출을 거부한 사람에 대한 과태료부과 결정(민집 75조 3항)
- ⑪ 강제경매신청을 기각하거나 각하하는 재판(민집 83조 5항)
- ⑫ 경매개시결정에 대한 이의신청에 관한 재판(민집 86조 3항)
- ⑬ 후행 경매개시결정에 기초하여 정지된 경매절차의 속행을 구하는 신청에 대한 재판 (민집 87조 5항)
- ⑭ 멸실 등에 의한 부동산 강제경매절차의 취소결정(민집 96조 2항)
- ⑮ 남을 가망이 없는 경우에 하는 부동산 강제경매절차의 취소결정(민집 102조 3항)
- ⑯ 직권으로 매각조건을 변경하거나 새로운 매각조건을 설정하는 재판(민집 111조 2항)
- ⑰ 부동산훼손의 경우 매각허가결정의 취소신청에 관한 결정(민집 127조 2항)
- ⑱ 매각허가 여부의 결정(민집 129조 1항, 2항)
- ⑲ 보증제공을 증명하는 서류를 붙이지 아니한 때에 하는 원심법원의 항고장각하 결정 (민집 130조 5항)
- ⑳ 부동산의 인도명령 신청과 관리명령 신청에 관한 결정(민집 136조 5항)
- ㉑ 부동산 강제관리신청을 기각하거나 각하하는 재판(민집 164조 4항)
- ㉒ 강제관리의 취소결정(민집 171조 3항)
- ㉓ 선박집행신청 전의 선박국적증서등 인도신청에 따른 재판(민집 175조 3항)
- ㉔ 압류선박 또는 항공기에 대한 운행허가결정(민집 176조 3항, 187조, 민집규 106조) 및 자동차·건설기계·소형선박에 대한 운행허가결정(민집 187조, 민집규 117조 3항, 130조)
- ㉕ 보증제공 등을 이유로 한 선박강제경매절차의 취소신청을 기각한 재판(민집 181조 3항)
- ㉖ 압류물을 제3자가 점유하게 된 경우의 인도명령신청에 관한 재판(민집 193조 5항) 84
- ㉗ 압류금지물건의 범위를 정하는 결정과 그 결정을 취소하거나 바꾸는 결정(민집 196조 4항)

- ㉘ 금전채권에 대한 압류명령신청에 관한 재판(민집 227조 4항)
- ㉙ 추심명령 또는 전부명령 신청에 관한 재판(민집 229조 6항)
- ㊱ 양도명령, 매각명령, 관리명령 등의 특별현금화명령(민집 241조 3항)
- ㊲ 압류금지채권의 범위를 정하는 결정과 그 결정을 취소하거나 바꾸는 결정(민집 246조 4항, 196조 4항)
- ㊳ 인도할 물건이 제3자의 점유에 있는 경우의 인도청구권에 대한 압류명령 및 인도청구권을 넘기라는 명령의 신청에 관한 재판(민집 259조, 227조 4항, 229조 6항)
- ㊴ 대체집행의 신청 및 대체집행비용 지급명령신청에 관한 재판(민집 260조 3항)
- ㊵ 간접강제신청에 관한 재판(민집 261조 2항)
- ㊶ 가압류·가처분 신청을 기각하거나 각하하는 결정(민집 281조 2항, 301조)
- ㊷ 가압류·가처분 이의신청에 관한 재판(민집 286조 7항, 301조)
- ㊸ 제소명령 불이행을 이유로 한 가압류·가처분 취소신청에 관한 재판(민집 287조 5항, 301조)
- ㊹ 사정변경 등에 따른 가압류·가처분 취소신청에 관한 재판(민집 288조 3항, 286조 7항, 301조)
- ㊺ 해방공탁금의 공탁을 이유로 한 가압류집행취소결정(민집 299조 3항)
- ㊻ 침해행위 방지를 위한 보전처분 및 그 취소 또는 변경결정(민집규 44조 5항)
- ㊼ 매각허가결정이 있는 뒤에 민사집행법 49조 2호의 서류가 제출되었음을 이유로 한 매수인의 매각허가결정취소신청에 관한 결정(민집규 50조 2항)
- ㊽ 자동차에 대한 강제경매개시결정(민집규 111조 4항)
- ㊾ 강제경매신청 전의 자동차인도명령신청에 관한 결정(민집규 113조 4항)
- ㊿ 간접강제결정 변경신청에 관한 결정(민집규 191조 3항)
- 85 ㊿ 선박을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매신청인에게 대항할 수 있는 권원을 가지지 아니한 선박 점유자에 대한 선박국적증서등 인도명령신청에 관한 재판(민집규 195조 3항)

다만 위에서 열거한 재판 중에는 집행절차에 관한 재판이 아니어서 그 재판에 대한 즉시항고에 민사집행법 15조가 적용되지 않고, 민사소송법상의 즉시항고에 관한 규정이 준용(민집 23조 1항)되는 경우 등이 있다.

첫째, ‘㉘ 재산조회를 받고 허위자료를 제출하거나 자료 제출을 거부한 사람에 대한 과태료 부과결정(민집 75조 2항)’은 민사집행법 15조 1항의 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 해

당하지 아니하고, 또한 집행절차의 특질을 고려하여 마련한 집행절차상의 즉시항고에 의하여 불복하도록 하는 것도 상당하지 않으므로, 위 과태료부과결정에 대한 즉시항고에는 민사집행법 15조가 적용되지 않고 비송사건절차법 248조 3항이 준용되어 집행정지의 효력이 인정된다(민집규 39조 2항).

한편 ‘㉓ 선박집행신청 전의 선박국적증서등 인도신청에 따른 재판(민집 175조 1항)’에 관하여도, 위 재판이 강제집행절차에 선행하는 준비절차 또는 일종의 보전처분이고 민사집행법 15조 1항의 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 해당하지 않으므로 위 재판에 대한 즉시항고에 민사집행법 15조가 적용되지 않는다는 견해가 있으나, 위 재판에 대한 즉시항고에 민사집행법 15조 6항이 적용되지 않고 민사소송법 447조가 준용된다고 보아 집행정지의 효력을 인정하는 것은 인도명령의 성질에 반하고 그 제도의 취지를 몰각시킴으로 위 재판에 대한 즉시항고에 민사집행법 15조가 적용된다고 보는 것이 타당하다.

둘째, ‘㉕ 가압류·가처분 신청을 기각하거나 각하하는 결정(민집 281조 2항, 301조)’, ‘㉖ 가압류·가처분 이의신청에 관한 재판(민집 286조 7항, 301조)’, ‘㉗ 제소명령 불이행을 이유로 한 가압류·가처분 취소신청에 대한 재판(민집 287조 5항, 301조)’, ‘㉘ 사정변경 등에 따른 가압류·가처분 취소신청에 대한 재판(민집 288조 3항, 286조 7항, 301조)’은 모두 보전소송에 관한 재판으로서 민사집행법 15조 1항의 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 해당하지 않으므로 민사집행법 15조가 적용되지 않고 민사소송법의 즉시항고에 관한 규정이 적용된다. 따라서 항고이유서를 제출하지 아니하였다거나 그 이유를 적어내지 아니하였다는 이유로 즉시항고를 각하할 수는 없다(대결 2006. 9. 28. 2006마829, 대결 2008. 2. 29. 2008마145). 다만 민사집행법은 ‘㉖ 가압류·가처분 이의신청에 관한 재판’, ‘㉗ 제소명령 불이행을 이유로 한 가압류·가처분 취소신청에 관한 재판’, ‘㉘ 사정변경 등에 따른 가압류·가처분 취소신청에 관한 재판’에 대한 즉시항고에는 민사소송법 447조의 준용을 배제하여 집행정지의 효력이 없는 것으로 규정하는 한편 일정한 요건을 갖춘 경우 가압류·가처분 취소결정의 효력을 정지시킬 수 있도록 하고 있다(민집 289조 1항).

그리고 집행비용액확정 결정은 집행종료 후의 재판으로서 민사집행법 15조 1항의 ‘집행절차에 관한 집행법원의 재판’에 해당하지 아니하고, 그 결정에 대하여는 민사집행규칙 24조 2항에 의하여 준용되는 민사소송법 110조 3항에 따라 민사소송법상의 즉시항고가 허용될 뿐이다. 따라서 집행비용액확정 결정에 대한 즉시항고에는 항고이유서 제출에 관한 민사집행법 15조 3항, 5항이 적용될 수 없다(대결 2011. 10. 13. 2010마1586).

3. 항고권자와 상대방

가. 항고권자

불복을 신청할 재판에 의하여 불이익을 받은 사람이다. 채권자, 채무자는 물론 제3자(매각허부결정에서의 매수인, 매수신고인, 채권압류에서의 제3채무자)도 항고할 수 있다. 그러나 절차의 안정성을 위하여 항고권자만이 항고권을 행사할 수 있고, 항고권자의 채권자가 항고권자를 대위하여 항고할 수는 없다고 해석하여야 할 것이다.

나. 상대방

87 항고절차는 편면적인 불복절차로서 판결절차에서와 같은 대립되는 당사자를 예상하고 있지 않으므로 엄격한 의미에서 상대방은 없다. 따라서 항고장에 반드시 피항고인의 표시가 있어야 하는 것은 아니고 또 항고장을 반드시 상대방에게 송달하여야 하는 것도 아니다(대결 1966. 8. 12. 65마473, 대결 1997. 11. 27. 97스4).

그러나 부동산의 인도명령(민집 136조), 압류물의 인도명령(민집 193조), 금전채권의 압류명령(민집 227조)과 같은 재판에 대해 채무자, 점유자, 제3채무자 등이 즉시항고를 제기한 경우 등에 원재판의 내용상 즉시항고인과 이해가 대립하는 사람이 생기는데, 실무에서는 항고심에서 원재판이 변경되는 때에 재항고의 기회를 주기 위하여 그를 상대방으로 정하여 심리에 관여시키고 결정문에 표시하며 통지도 하는 예가 적지 않다. 매각허부결정에 대한 항고에서는 항고법원이 필요한 경우에 반대진술을 하게 하기 위하여 항고인의 상대방을 정할 수 있다고 명문의 규정을 두고 있다(민집 131조 1항).

[전산양식 A3102] 항고인의 상대방을 정하는 결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건 20 라	매각허가결정에 대한 항고 항 고 인
위 사건에 관하여 반대의 진술을 하게 하기 위하여 아래의 사람을 상대방으로 정한다.	
아 래	
채 권 자 ○ ○ ○	

서울 ○○구 ○○로 ○○			
2000. ○. ○.			
재판장 판사	○	○	○
판사	○	○	○
판사	○	○	○

4. 즉시항고의 제기방법

88

가. 항고장과 항고이유서의 제출(서면주의)

즉시항고는 항고권자가 항고장을 작성하여 원심법원에 제출하는 방법으로 제기한다(민집 15조 2항). 반드시 서면을 제출하여야 하고 말로는 제기할 수 없다. 민사집행의 신청과 같이 절차의 안정성을 위하여 서면주의를 채택하고 있다.

그 항고장에 당사자와 법정대리인, 불복을 제기하는 원심법원의 재판의 표시와 그 재판에 대한 항고의 취지를 적어야 한다(민소 397조 2항 준용). 또한, 항고장에는 항고이유를 적을 수 있는데, 이를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 원심법원에 제출하여야 한다(민집 15조 3항).

사법보좌관의 처분 중 단독판사 등이 처리하는 경우 즉시항고의 대상이 되는 처분에 대하여는 사법보좌관에게 이의신청서를 제출하여야 하고, 사법보좌관으로부터 이의신청 사건을 송부받은 단독판사 등이 이의신청이 이유 없다고 인정하여 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부한 경우 그 이의신청서는 항고장으로 취급된다(사보규 4조 1항, 2항, 6항 5호).

제1편
제5장
제2절

나. 항고장의 제출기간 및 제출법원

항고권자는 재판을 고지받은 날부터 1주의 불변기간 이내에 항고장을 원심법원에 제출하여야 한다(민집 15조 2항).

즉시항고를 할 수 있는 사람이 재판을 고지받아야 할 사람이 아닌 경우 즉시항고의 제기기간은 그 재판을 고지받아야 할 사람 모두에게 고지된 날부터 진행한다(민집규 12조). 민사집행절차에 관한 재판을 고지받을 사람의 범위는 민사집행규칙 7조와 그 특례규정인 100조 2항, 124조 2항 등에 규정되어 있지만, 즉시항고를 제기할 수 있는 사람은 그 재판

에 관하여 법률상의 이해관계가 있는 사람으로 해석되므로, 그 범위가 반드시 명확한 것은
 89 아니다. 따라서 민사집행법 15조 2항의 “재판을 고지받은 날”의 의미를 당해 항고인이
 재판을 고지받은 날로 한정하여 해석하게 되면 재판을 고지하여야 할 사람을 특정하기
 어렵고 당해 재판의 확정 여부가 불확실하게 될 우려가 있다. 그러므로 재판을 고지받은
 사람은 민사집행규칙 7조와 그 특례규정인 100조 2항, 124조 2항에 규정한 사람으로 한
 정하고 즉시항고를 할 수 있는 사람이 재판을 고지받아야 할 사람이 아닌 경우 즉시항고의
 제기기간은 그 재판을 고지받아야 할 사람 모두에게 고지된 날부터 진행하도록 한 것이다.
 그러나 매각을 허가하거나 허가하지 아니하는 결정은 선고한 때에 고지의 효력이 발생하
 므로(민집규 74조), 그에 대한 즉시항고의 제기기간은 선고일로부터 진행한다.

1주의 기간은 불변기간이므로 불변기간에 관한 민사소송법의 규정, 예를 들어 소송행위의
 추후보완에 관한 민사소송법 173조와 부가기간에 관한 민사소송법 172조 2항, 3항이 준용
 된다. 다만 민사집행규칙 7조 등에 재판을 고지받을 사람으로 규정되지 않은 사람이 재판을
 고지받지 못하여 즉시항고기간을 지킬 수 없었다는 사정은 특별한 사정이 없는 한 추완항고
 에서 그 책임질 수 없는 사유에 해당하지 않는다(대결 1980. 8. 21. 80마183 참조).

즉시항고장이 항고법원에 직접 제출된 경우의 처리에 관하여는 ① 민사소송법 34조 1항
 을 유추하여 원심법원에 이송할 것이라는 견해와 ② 남항고의 방지와 집행절차의 신속을
 중시하여 바로 각하할 것이라는 견해가 있다. 항고법원의 운용으로서는, 항고인이 직접
 항고장을 지참한 때에는 원심법원에 제출하도록 창구지도를 하고, 우송되어온 경우에는
 항고인 제출의 송달료를 이용하여 원심법원에 송부해 주는 방법이 무난할 것이다. 이 경우
 에 기간 준수 여부는 항고장이 원심법원에 접수된 때를 기준으로 하여 결정한다(대결
 1992. 4. 15. 92마146).

항고장을 원심법원에 제출하였는데, 다만 그 명칭을 “항고장”이라고 기재하지 아니하고
 “재항고장” 또는 “특별항고장”이라고 기재하는 바람에 원심법원이 이를 대법원에 송부하
 거나 항고법원이 대법원으로 이송한 경우에는 이를 관할법원인 항고법원에 이송하여야 하
 90 고(대결 2002. 10. 23. 2002그73), 즉시항고만이 허용되는 집행법원의 재판(매각허가결
 정)에 대하여 “이의신청”이라는 제목으로 제출된 불복은 이를 즉시항고로 보아 처리하여야
 한다(대결 1994. 7. 11. 94마1036).

한편 즉시항고가 가능한 시점과 관련하여, 대법원은 당사자에게 고지되지 아니하여 효
 력이 발생하지 아니한 결정 등에 대한 항고는 부적법하다는 종전 입장을 변경하여, 결정
 등의 원본이 법원사무관등에게 교부되어 성립한 경우에는 그것이 당사자에게 고지되어 효

력이 발생하기 전에도 이에 불복하여 항고할 수 있다고 하였다[대결(전) 2014. 10. 8. 2014마667].

항고장에는 민사소송 등 인지법 11조에서 정한 인지를 붙여야 한다.

사법보좌관의 처분 중 단독판사 등이 처리하는 경우 즉시항고의 대상이 되는 처분에 대하여는 그 처분을 고지받은 날부터 7일 이내에 사법보좌관에게 이의신청서를 제출하여야 한다(사보규 4조 1항, 2항, 3항).

5. 항고이유서 제출의 강제

민사집행법은 15조를 규정하면서, 항고장에 항고이유를 적지 아니하는 때에는 항고인은 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 하고(3항), 항고이유서를 제출하지 않은 때에는 원심법원이 즉시항고를 각하하며(5항), 항고법원은 원칙적으로 항고장 또는 항고이유서에 적힌 이유에 대하여서만 조사하도록 하여(7항) 항고이유서 제출강제주의를 채택하였다. 집행절차와 같이 실체적 판단 부분은 적고 또한 쟁점도 비교적 명확한 경우가 대부분인 분야에서는 단기간에 항고이유를 명백히 밝히도록 하더라도 당사자의 권리보호에 불충분하다고 할 수 없고, 또한 당사자 이외에 제3자가 관여하는 것이 예상되는 집행절차에서는 제3자와의 이해조정도 고려할 필요가 있으며, 특히 집행절차의 생명이라고 할 수 있는 신속성을 확보할 필요가 있기 때문이다.

항고이유서를 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 제출하도록 제한한 목적은 집행절차의 적정·신속성을 도모하기 위한 것이므로, 즉시항고의 이유도 그 목적에 합치되도록 명확히 적어야 한다. 즉, 즉시항고의 이유는 원심재판의 취소 또는 변경을 구하는 사유를 구체적으로 적어야 하고(민집규 13조 1항), 그 사유가 법령위반인 때에는 그 법령의 조항 또는 내용과 법령에 위반되는 사유를, 그 사유가 사실의 오인인 때에는 오인에 관계되는 사실을 구체적으로 밝혀야 한다(민집규 13조 2항). 즉시항고는 원심재판 당시의 하자뿐만 아니라 그 후 항고이유서 제출 시까지 생긴 사유도 이유로 할 수 있으므로, “원심재판이 위법한 이유” 등의 표현 대신에 “원심재판의 취소 또는 변경을 구하는 사유”를 적도록 하였다.

10일의 항고이유서 제출기간이 불변기간이 아니라 통상의 법정기간이므로(대결 2009. 4. 10. 2009마519), 민사소송법 172조를 준용하여 법원이 그 기간을 늘리는 것은 허용되는 반면, 민사소송법 173조가 규정하는 소송행위의 추후보완은 인정되지 않는다.

사법보좌관의 처분 중 단독판사 등이 처리하는 경우 즉시항고의 대상이 되는 처분에

대한 이의신청과 관련하여, 2014. 9. 1. 개정 전의 구 사법보좌관규칙 4조는 이의신청을 하는 때에 민사소송 등 인지법 또는 해당 법률에서 정하는 인지, 보증제공서류 등을 붙일 필요가 없고(4항), 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부하는 경우에 있어서 이의신청에 인지, 보증제공서류 등이 붙어 있지 아니하거나 이의신청이 해당 법률에 규정된 항고 또는 즉시항고의 요건을 갖추지 아니한 때에는 상당한 기간을 정하여 이의신청인에게 보정을 명하도록(6항 6호) 규정하였기 때문에 항고이유서가 이의신청서 제출일부터 10일 이내에 제1심법원에 제출되지 않았다는 이유만으로 즉시항고(이의신청이 즉시항고로 간주된 것)를 각하할 수는 없었다(대결 2009. 4. 10. 2009마519). 그러나 2014. 9. 1. 개정된 사법보좌관규칙 4조에 따르면, 이의신청을 하는 때에 인지 외에 항고절차의 요건이 되는 서류 등은 민사집행법 등의 규정에 따라 제출하여야 하고(4항, 10항), 이를 위반하는 경우에는 이의신청이 부적법하므로 단독판사 등은 결정으로 이의신청을 각하하여야 하며(6항 2호), 단독판사 등이 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청 사건을 항고법원에 송부하는 경우에 있어서의 보정명령은 인지에 관하여만 한다(6항 6호). 92 사법보좌관규칙의 상위법인 민사집행법 등이 규정한 집행절차의 지연방지 및 남항고 방지라는 입법취지에 배치되지 않도록 조치한 것으로서, 이로써 항고이유서 제출강제주의는 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 경우에도 그대로 적용되게 되었다.

한편 항고이유서 제출강제주의는 민사집행법 15조 1항의 '집행절차에 관한 집행법원의 재판'에 대한 즉시항고에 적용되는데, 가압류·가처분 신청을 기각하거나 각하하는 결정, 가압류·가처분 이의신청에 대한 재판, 제소명령 불이행을 이유로 한 가압류·가처분 취소 신청에 대한 재판, 사정변경 등에 따른 가압류·가처분 취소신청에 대한 재판이나 집행비용액 확정결정은 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 해당하지 아니하여 그에 대한 즉시항고에는 민사소송법상의 즉시항고에 관한 규정이 적용되므로, 항고인이 항고이유서를 제출하지 아니하였다거나 그 이유를 적어내지 아니하였다는 이유로 그 즉시항고를 각하할 수는 없다(대결 2006. 9. 28. 2006마829, 대결 2008. 2. 29. 2008마145, 대결 2011. 10. 13. 2010마1586).

6. 원심법원의 처리

가. 즉시항고가 부적법하거나 즉시항고에 흠이 있는 경우

항고인이 항고장에 항고이유를 적지 않고 또한 항고장 제출일로부터 10일 이내에 항고

이유서를 제출하지 않은 경우에는 원심법원은 결정으로 그 즉시항고를 각하하여야 한다(민집 15조 5항).

항고장에 항고이유의 기재가 있거나 항고이유서를 제출하였지만, 그 항고이유의 기재가 민사집행규칙 13조에 정한 기재방법을 위반한 경우(예를 들어, 법령위반을 주장하면서도 어느 법령을 위반하였는지 구체적으로 적지 않은 경우 또는 사실오인을 주장하면서도 오인에 관계되는 사실을 구체적으로 밝히지 않은 경우)에도 원심법원은 결정으로 그 즉시항고를 각하하여야 한다(민집 15조 5항). 그러나 이 경우에는 일응 항고이유의 기재 등은 93 있고 이유의 당부 판단은 항고법원의 전권에 속하므로 이유의 기재방법이 명백하게 정해진 방식을 위반하였다고 인정되는 경우에 한하여 원심법원이 즉시항고를 각하할 수 있다고 할 것이다. 반면 기재된 항고이유가 누가 보아도 부당하다 하더라도 정해진 방식에 따른 이유의 기재가 있는 이상 원심법원이 즉시항고를 각하할 수는 없다.

즉시항고가 부적법하고 이를 보정할 수 없음이 분명한 때에도 원심법원은 결정으로 그 즉시항고를 각하하여야 한다(민집 15조 5항). 즉시항고가 허용되지 않은 재판에 대하여 즉시항고를 제기한 경우나 즉시항고를 제기할 수 없는 사람이 즉시항고를 제기한 경우(예를 들어, 민사집행법 90조 각 호에서 열거한 사람에 해당하지 아니한 사람이 제기한 매각허가결정에 대한 즉시항고, 대결 2005. 5. 19. 2005마59)가 이에 해당한다는 데에는 문제가 없다. 그러나 항고제기기간 경과 후에 항고장이 제출된 경우에는 소송행위의 추후보완과 관련하여 약간의 문제가 있다. 항고인이 추후보완의 주장을 하면서 항고장을 제출한 경우에는 추후보완의 요건에 대한 증명 여부에 따라 항고제기가 적법하게 될 수도 있어서 “항고가 부적법하고 이를 보정할 수 없음이 분명한 때”에 해당한다고 할 수 없으므로 원심법원이 즉시항고를 각하할 수 없지만, 항고인이 추후보완의 주장 없이 기간 경과 후 항고장을 제출한 경우에는 원심법원이 즉시항고를 각하할 수 있다고 할 것이다.

한편 매각허가결정에 대하여 즉시항고를 제기하면서 항고장에 보증을 제공하였음을 증명하는 서류를 붙이지 아니한 때에는 원심법원은 항고장을 받은 날부터 1주 이내에 결정으로 항고장을 각하하여야 한다(민집 130조 4항).

이와 달리 즉시항고에 보정할 수 있는 하자가 있는 경우, 예를 들어 항고장이 민사소송법 397조 2항의 규정에 어긋나거나 항고장에 민사소송 등 인지법 11조에서 정한 인지를 붙이지 아니한 경우에는 민사집행법 15조 10항, 민사소송법 443조 1항에 의하여 민사소송법 399조를 준용하여 원심법원의 재판장이 상당한 기간을 정하여 보정을 명하고 그 기간 내에 보정하지 않는 경우에는 명령으로 항고장을 각하(항고장각하명령)하여야 한다.

- 94 항고인은 원심법원의 항고각하결정, 항고장각하결정이나 원심법원 재판장의 항고장각하명령에 대하여 즉시항고를 할 수 있다(항고각하결정에 관하여는 민집 15조 8항, 항고장각하결정에 대하여는 민집 130조 5항, 항고장각하명령에 관하여는 민소 399조 3항 준용). 항고제기기간 경과를 이유로 한 항고각하결정에 대하여 즉시항고를 제기하면서 추후 보완의 주장을 하는 것은 허용된다고 할 것이다.

원심법원의 항고각하결정 등에 대한 즉시항고[이른바 재도(再度)의 즉시항고]는 일반의 즉시항고와 차이가 있는 것은 아니므로 일반의 즉시항고에 관한 절차가 그대로 적용된다. 즉, 항고인이 항고각하결정 등을 고지받은 날부터 1주의 불변기간 이내에 항고장을 원심법원에 제출하여야 하고(민집 15조 2항), 항고장에 항고이유(원재판에 대한 항고이유가 아니라 항고각하결정 등에 대한 항고이유)를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 원심법원에 제출하여야 한다(민집 15조 3항). 또한, 이 즉시항고에 대하여 정해진 기간 내에 항고이유서를 제출하지 아니하거나 항고이유가 정해진 방식에 위반한 때 또는 항고가 부적법하고 이를 보정할 수 없음이 분명한 때에는 원심법원은 결정으로 그 즉시항고를 각하하여야 한다(민집 15조 5항).

- 그런데 집행법원의 종전 항고각하결정 등에 대한 새로운 항고각하결정에 대하여도 즉시항고를 할 수 있기 때문에(민집 15조 8항) 이론적으로는 언제까지나 즉시항고의 기회가 남아 있다. 그러나 이러한 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 않기 때문에(민집 15조 6항) 항고각하결정에 대하여 즉시항고가 제기되더라도 원처분에 대한 즉시항고가 각하된 상태는 그대로 지속되는 것이어서 특별한 불합리는 생기지 않는다. 즉시항고의 제기로 절차가 정지되는 경우(예를 들어, 민집 17조 1항의 재판, 매각허가여부결정, 선박운행허가결정, 전부명령, 채권의 특별현금화명령 등에 대한 즉시항고가 있는 경우)에도 최초의 즉시항고가 각하되면 그 즉시항고의 대상이 된 원재판의 효력이 발생하여 후속 절차가 진행되기 때문에 항고의 이익이 없어지게 되는 경우가 많을 것이다. 따라서 즉시항고의 기회가 계속 보장된다고 하더라도 절차적으로 문제가 되는 것은 적을 것이다. 또한, 원심법원의 항고각하와 절차방해를 목적으로 한 즉시항고가 계속 되풀이될 것으로 예상되는 경우에는 원심법원에서 항고를 각하하지 않고 항고법원에서 항고를 각하하는 것도 가능하다.
- 95

판례도 매각허가결정에 대하여 즉시항고가 제기되었는데 원심법원이 보증의 제공이 없음을 이유로 항고장각하결정(민집 130조 4항)을 한 경우에 항고장각하결정에 관하여는 '확정되어야 효력이 있다'는 규정이 없고 그 각하결정에 대한 즉시항고(민집 130조 5항)에는 집행정지의 효력이 없어서(민집 15조 6항) 그 각하결정에 대한 즉시항고로 매각허가결

정의 확정이 차단되지 아니하므로, 강제집행(강제경매)절차는 정지되지 않는다고 하였다(대결 1995. 1. 20. 94마1961). 이처럼 항고각하결정 등에 대한 즉시항고가 제기되더라도 집행절차는 그대로 진행되므로, 항고각하결정 등에 대하여 다시 즉시항고를 제기하면서 집행절차의 전부 또는 일부를 정지시킬 필요가 있는 때에는 원심법원으로부터 별도의 집행정지 재판을 받아야 한다(민집 15조 6항).

나. 즉시항고가 적법한 경우

적법한 즉시항고가 제기된 경우 원심법원인 집행법원이 스스로 항고가 이유 있다고 인정하는 때에는 그 재판을 경정하여야 하고[민소 446조 준용, 재도(再度)의 고안(考案)], 이로써 항고절차가 종료된다. 한편 재도의 고안에 의하여 원재판이 변경되거나 취소되는 때에는 그때 새로운 처분이 있는 것이므로, 그 새로운 처분의 내용에 따라 이에 대한 불복방법이 정하여진다.

그러나 그 항고가 이유 없다고 인정한 때에는 원심법원의 법원사무관등은 항고장이 제출된 날부터 2주 이내에(흠을 보정하도록 명한 때에는 그 흠이 보정된 날부터 1주 이내에) 원칙적으로 항고사건의 기록 외에 집행사건의 기록도 항고법원으로 보내야 한다(민소 400조 1항, 2항 준용).

다만 원심법원인 집행법원이 상당하다고 인정하는 때에는 항고사건의 기록만을 보내거나 집행사건의 기록 일부의 등본을 항고사건의 기록에 붙여 보낼 수 있고(민집규 14조 1항) 96 이 경우 항고법원은 필요하다고 인정하는 때에는 집행사건의 기록 또는 필요한 등본의 송부를 요구할 수 있다(민집규 14조 2항).

‘매각허가결정에 대하여 보증의 제공이 있음을 증명하는 서류를 첨부하지 아니하고 항고를 한 경우의 업무처리요령’(재민 95-2)에서는 보증제공 증명서류를 첨부하지 않음을 이유로 한 항고장각하결정에 대하여 불복신청이 있는 경우, 경매기록은 원심법원에 그대로 두어 경매절차를 속행하고, 항고법원에는 ① 경매기록 표지의 등본, ② 매각허가결정의 등본, ③ 항고장의 등본, ④ 항고장각하결정의 등본 및 그 송달현황목록, ⑤ 항고장각하결정에 대한 불복신청서, ⑥ 항고인이 불복신청서 이후에 제출한 서류 중 당해 불복신청과 관련된 서류를 편철하여 작성한 ‘경매기록 일부의 등본 등’만을 송부하도록 규정하고 있다. 이러한 즉시항고사건은 사안이 간명하여 그러한 조치만으로도 항고법원이 판단하는데에 충분하기 때문에, 위 예규는 항고장각하명령(민소 399조 준용)이나 항고각하결정(민집 15조 5항)에 대한 즉시항고사건에도 유추적용되어야 할 것이다.

다. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 경우

사법보좌관은 이의신청을 받은 때에는 재도의 고안을 하여 원처분을 경정할 수 있다. 이와 같은 재도의 고안은 이의신청이 있는 경우에만 가능하다. 사법보좌관은 원처분을 유지할 경우에는 이의신청사건을 지체 없이 소속법원의 단독판사 등에게 송부하여야 한다(사보규 4조 5항).

지방법원 합의부가 재판한 민사합의사건에 관한 소송비용액 확정신청에 대하여 한 사법보좌관의 처분을, 본안사건의 주소법원이라고 할 지방법원 합의부가 아닌 단독판사가 인가하는 것은 전속관할 위반이므로(대결 2008. 6. 23. 2007마634), 이러한 경우 사법보좌관은 이의신청사건을 단독판사가 아닌 합의부에 송부하여야 한다. 지방법원 합의부가 재판한 가처분결정에 관하여 제기된 제소명령신청을 기각 또는 각하한 사법보좌관의 처분에 대하여 이의신청이 있는 경우 등에도 마찬가지이다.

- 97 사법보좌관으로부터 이의신청사건을 송부받은 단독판사 등은 다음과 같이 처리하여야 한다(사보규 4조 6항, 10항).

(1) 이의신청이 사법보좌관규칙 4조 2항의 규정에 위배되는 경우에는 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 흠을 보정하도록 명하여야 한다.

(2) 이의신청인이 흠을 보정하지 아니하는 때와 이의신청기간을 경과한 때에는 결정으로 이의신청을 각하한다. 그리고 매각허가결정에 대하여 이의신청을 하면서 그 이의신청서에 보증을 제공하였음을 증명하는 서류를 붙이지 아니한 때에는 이의신청서를 받은 날부터 1주 이내에 결정으로 이의신청서를 각하하여야 하고, 이의신청서에 민사집행규칙 13조가 규정하는 항고이유를 구체적으로 적거나 이의신청서를 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서에 준하는 서면을 제출하지 아니한 경우에는 결정으로 이의신청을 각하해야 한다. 이 경우 각하결정은 해당 법률에 규정된 불복신청에 대한 각하재판으로 본다.

(3) 이의신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 사법보좌관의 처분을 경정한다.

(4) 이의신청이 이유 없다고 인정되는데 이의신청에 민사소송 등 인지법에서 정하는 인지가 납부되지 아니한 때에는 상당한 기간을 정하여 이의신청인에게 보정을 명하고, 이의신청인이 보정하지 아니한 때에는 이의신청을 각하한다.

(5) 이의신청이 이유 없다고 인정되고 즉시항고의 요건이 갖추어진 때에는 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부한다. 이 경우 인가결정은 이의신청인에게 고지하며, 이의신청은 해당 법률에 의한 즉시항고로 본다.

한편 사법보좌관의 처분에 대하여 이의신청을 하는 취지의 즉시항고장이 제출되면 사법

보좌관은 사건기록을 소송법원의 단독판사 등에게 송부하는 등 사법보좌관규칙 4조 5항, 6항이 정하는 절차를 거쳐야 함에도 이러한 절차를 거침이 없이 곧바로 항고법원에 사건 기록을 송부하였다면, 항고법원으로서의 사건기록을 다시 제1심법원에 이송하여 적법한 절차를 거치도록 하여야 한다(대결 2008. 9. 25. 2008마922).

7. 집행정지

98

민사소송법상의 즉시항고는 집행을 정지시키는 효력을 가지나(민소 447조), 민사집행법상의 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 않는다(민집 15조 6항).

한편 즉시항고를 할 수 있는 재판 중에서 확정되어야 효력이 발생하는 것으로는 ① 집행절차를 취소하거나 집행관에게 집행절차의 취소를 명하는 결정(민집 17조 2항), ② 매각허가여부결정(민집 126조 3항), ③ 선박운행허가결정(민집 176조 4항), ④ 전부명령(민집 229조 7항), ⑤ 채권의 특별현금화명령(민집 241조 4항) 등이 있는데, 이 경우에는 즉시항고 자체가 확정을 차단시킴으로써 결정의 효력 발생을 정지시키는 효과가 있으므로 따로 집행정지의 처분이 필요 없다. 이 재판에 대하여 즉시항고를 제기하였음에도 집행절차를 진행하는 경우에는 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다.

그러나 확정되어야 효력이 발생하는 재판이 아닌 재판에 대하여는 즉시항고를 제기하더라도 당연히 집행이 정지되지는 않는다. 이 경우 항고법원(재판기록이 원심법원에 남아 있는 때에는 원심법원)은 즉시항고에 대한 결정이 있을 때까지 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하게 하지 아니하고 원심재판의 집행을 정지하거나 집행절차의 전부 또는 일부를 정지하도록 명할 수 있고, 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명할 수 있다(민집 15조 6항 단서).

집행정지를 명하는 결정 또는 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명하는 결정에 대하여는 불복할 수 없으므로(민집 15조 9항), 특별항고만이 가능하다.

한편 집행정지 등의 재판은 항고법원이 직권으로 하는 것이고 당사자에게 신청권이 있는 것이 아니므로, 당사자의 집행정지신청은 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없다. 따라서 법원은 이 신청에 대하여는 재판을 할 필요가 없고, 설령 법원이 이 신청을 거부하는 재판을 하였다고 하여도 불복이 허용되지 아니하므로 그에 대한 불복으로서 특별항고도 부적법하다(대결 2004. 10. 14. 2004그69 등).

사법보좌관의 처분에 대한 이의신청사건을 송부받은 단독판사 등은 그 사건을 처리함에 99

있어 해당 법률에 규정된 절차에 따라 사법보좌관의 처분에 대하여 그 집행을 정지하거나 그 밖의 필요한 처분을 할 수 있다(사보규 4조 6항).

8. 항고법원의 심리와 재판

가. 항고장각하명령

즉시항고에 대하여는 민사집행법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민사소송법 제3편 제3장 중 즉시항고에 관한 규정을 준용하고(민집 15조 10항), 민사소송법은 항고법원의 소송절차에는 항소에 관한 규정을 준용하고 있으므로(민소 443조 1항), 항소심재판장의 항소장심사권을 규정한 민사소송법 402조가 즉시항고에 대한 재판에 준용된다.

따라서 항고장이 민사집행법 15조 4항, 민사집행규칙 13조의 규정에 어긋나거나 항고장에 민사소송 등 인지법 11조에서 정한 인지를 붙이지 아니한 경우에 항고법원 재판장은 항고인에게 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 흠을 보정하도록 명하여야 하고, 항고인이 그 기간 내에 흠을 보정하지 아니한 때에는 항고심재판장은 명령으로 항고장을 각하하여야 한다.

나. 항고각하결정

위와 같은 사유가 있었으나 항고심재판장의 심사단계에서 그러한 흠을 발견하지 못하여 항고법원이 조사에 들어갔다가 뒤늦게 위와 같은 흠을 발견한 경우에는 항고법원이 보정을 명하여야 하고 항고인이 이에 응하지 아니하는 경우에는 항고법원이 결정으로 즉시항고를 각하하여야 한다.

또한, 항고법원은 원심재판의 당부에 관하여 실질조사에 들어가기 전에 즉시항고의 적법성을 조사하여 즉시항고가 부적법한 때에는 역시 결정으로 즉시항고를 각하하여야 한다. 예를 들어, 민사집행법 90조 각 호에서 열거한 사람에 해당하지 아니한 사람이 한 매각허가결정에 대한 즉시항고는 부적법하고 또한 보정할 수 없음이 분명하므로 민사집행법 15조 5항에 의하여 집행법원이 결정으로 즉시항고를 각하하여야 하는데, 집행법원이 항고각하결정을 하지 않은 채 항고심으로 기록을 송부한 경우에는 항고심에서 항고를 각하하여야 한다(대결 2005. 5. 19. 2005마59).

즉시항고가 부적법한 때에는 항고법원은 원심재판의 당부에 관하여 실질조사를 할 수 없고, 설령 원심재판에 영향을 미친 법령위반 또는 사실오인의 위법이 있다고 하더라도 원심재판을 변경할 수 없다.

다. 항고법원의 심리와 재판

항고법원은 원칙적으로 항고장 또는 항고이유서에 적힌 이유에 대하여서만 조사하되, 다만 원심재판에 영향을 미칠 수 있는 법령위반 또는 사실오인이 있는지에 대하여 직권으로 조사할 수 있다(민집 15조 7항).

그 밖의 항고법원의 심리와 재판에 대하여는 민사소송법 제3편 제3장 중 즉시항고에 관한 규정이 준용된다(민집 15조 10항).

따라서 항고법원은 항고이유와 직권조사사항을 심리하기 위하여 변론을 열 수 있고(민소 134조 1항 준용), 변론을 열지 아니할 경우에는 당사자와 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있으며(민소 134조 2항 준용), 서면심리만으로 조사를 마칠 수도 있다. 다만 항고법원이 즉시항고에 대한 재판을 유보하여야 하는 경우로서 민사집행법 229조 8항이 있다. 전부명령이 있는 뒤에 집행정지문서(민집 49조 2호 또는 4호의 서류)를 제출한 것을 이유로 전부명령에 대한 즉시항고가 제기된 경우에 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 민사집행법 229조 8항에 따라 항고에 관한 재판을 정지하여야 하고, 그 후 잠정적인 집행정지가 종국적인 집행취소나 집행속행으로 결말이 나는 것을 기다려, 집행취소로 결말이 난 때에는 항고를 인용하여 전부명령을 취소하고, 집행속행으로 결말이 난 때에는 항고를 기각하여야 한다(대결 2004. 7. 9. 2003마1806, 대결 2008. 11. 13. 2008마1140 등).

항고법원은 심리 결과 항고에 정당한 이유가 있거나 원심재판에 영향을 미칠 수 있는 법령위반 또는 사실오인이 있는 경우에는 결정으로 원심재판을 경정하여야 한다(민소 446조 준용). 즉, 원심결정을 변경하거나 원심결정을 취소하고 새로 상당한 재판을 하여야 한다. 다만 매각허부결정에 대한 즉시항고의 경우에는 항고법원은 즉시항고에 정당한 이유가 있는 경우 원심재판을 취소하여 집행법원에 사건을 환송하여야 하고, 새로 매각허가여부의 결정을 할 수 없음(민집 132조)에 유의하여야 한다.

항고법원은 심리 결과 항고에 정당한 이유가 없고 직권으로 원심재판을 취소할 만한 위법이 없는 경우에는 결정으로 항고를 기각하여야 한다.

라. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청의 경우

사법보좌관의 처분에 대하여는 일반적인 불복제도가 적용되지 않고 별도의 이의신청 제도가 적용되므로, 사법보좌관의 처분 자체는 항고법원의 심판대상이 될 수 없고, 사법보

101

제1편
제5장
제2절

좌판으로부터 이의신청사건을 송부받은 단독판사 등의 재판이 그 심판대상이 될 수 있을 뿐이다.

즉, 단독판사 등이 이의신청이 이유 없다고 인정하여 사법보좌관의 처분을 인가하고 이의신청사건을 항고법원에 송부한 경우[사보규 4조 6항 5호, 이 때 인가결정을 이의신청인에게 고지하여야 한다(사보규 4조 6항 5-2호)]에는 그 인가처분이 항고법원의 심판대상으로 되므로, 그 이의신청사건을 송부받은 항고법원은 단독판사 등이 한 인가처분에 대한 즉시항고로 보아 재판절차를 진행하게 된다(사보규 4조 9항).

한편 단독판사 등이 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청이 부적법하다는 이유로 이를 각하하는 재판을 한 경우(사보규 4조 6항 2호, 6호)나 이의신청이 이유가 있다고 인정하여 사법보좌관의 처분을 경정한 경우(사보규 4조 6항 3호)에는 그 각하재판이나 경정재판에 대하여 해당 법률에서 정한 절차에 따라 불복할 수 있으므로(사보규 4조 7항), 이에 대하여 다시 즉시항고가 제기되면 그 각하재판이나 경정재판이 항고법원의 심판대상으로 된다.

102 9. 항고법원의 재판에 대한 재항고

즉시항고에 관한 항고법원의 재판에 대하여는 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반을 이유로 드는 때에만 재항고할 수 있다(민소 442조 준용). 이 재항고도 즉시항고에 해당한다. 따라서 인도명령, 채권압류 및 추심명령, 간접강제결정에 대한 즉시항고(민집 136조 5항, 227조 4항, 229조 6항, 261조 2항)와 같은 민사집행법상의 즉시항고에 관한 항고법원의 재판에 대한 재항고절차에는 민사집행법상의 즉시항고와 재항고에 관한 규정이 준용되므로, 제1심의 인도명령 등에 대한 즉시항고를 기각한 원심의 항고기각결정에 대하여 재항고인이 재항고를 제기하면서 10일 이내에 재항고이유서를 제출하지 않은 경우, 원심으로서의 결정으로 재항고를 각하하여야 하고, 원심이 이를 각하하지 않은 때에는 대법원이 재항고를 각하하여야 한다(대결 2004. 9. 13. 2004마505, 대결 2008. 4. 25. 2008마228, 대결 2015. 4. 10. 2015마106).

그리고 집행절차에 관한 항고법원·고등법원 또는 항소법원의 결정 및 명령으로서 즉시항고를 할 수 있는 재판에 대하여도 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반을 이유로 드는 때에만 재항고할 수 있고(민집규 14조의2 1항), 그 재항고에 관하여도 민사집행법 15조를 준용한다(민집규 14조의2 2항).

제3절 집행에 관한 이의신청

1. 의의

집행법원의 집행절차에 관한 재판으로서 즉시항고를 할 수 없는 것과 집행관의 집행처분, 그 밖에 집행관이 지킬 집행절차에 대하여서는 법원에 이의신청을 할 수 있다(민집 16조 1항).

집행관이 집행위임을 거부하거나 집행행위를 지체하는 경우 또는 집행관이 계산한 수수료에 관하여 이의가 있는 때에도 집행에 관한 이의신청으로 다룰 수 있다(민집 16조 3항). 103

2. 이의의 대상

가. 집행법원의 집행절차에 관한 재판으로서 즉시항고를 할 수 없는 것

즉시항고가 허용되는 집행법원의 재판에 대하여는 집행에 관한 이의를 신청할 수 없다.

여기서 재판이란 법원 또는 법관(사법보좌관)의 판단행위를 가리키고 재판에 해당하는 한 그것이 집행기관으로서 행한 것인지의 여부는 묻지 않는다.

따라서 공휴일과 야간 집행의 허가(민집 8조)에 대하여도 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다. 그러나 재판이 아닌 사실행위(예를 들어, 매각물건명세서의 작성, 민집 105조 1항)에 대하여는 집행에 관한 이의신청을 할 수 없다는 견해와 이를 제외하는 경우 사실상 불복방법이 없다는 점에서 그 유추적용이 가능하다는 견해로 나뉘어 있다.

집행절차란 집행신청에 의하여 개시된 구체적인 집행절차를 말하고 그 준비를 위한 절차는 이에 포함되지 아니하므로, 집행문을 내어달라는 신청이 거절된 때에는 집행에 관한 이의신청을 할 수 없다. 집행문을 내어 달라는 신청에 대한 불복방법은 뒤에서 본다.

서로 모순 저촉되는 점유이전금지가처분집행이 경합하는 경우의 불복방법(대결 1981. 8. 29. 81마86), 경매신청취하의 하자에 관한 불복방법(대결 1987. 3. 24. 86마카51), 공탁사유 신고 불수리결정에 대한 불복방법(대결 1997. 1. 13. 96그63), 경매절차취소사유가 있음에도 집행법원이 취소결정을 하지 않을 경우의 불복방법(대결 1997. 11. 11. 96그64), 경매절차에서 배당기일에 불출석한 채무자가 자신에게 공탁된 배당 잔여액의 출금을 위하여 집행법원에 지급위탁서의 송부와 자격증명서의 교부를 신청하였다가 거절당한 경우의 불복방법(대결 1999. 6. 18. 99마1348), 가처분결정 등 집행처분의 취소를 명한 취지를 적은 재판의 정보 104

제출에 따른 간접강제결정취소결정에 대한 불복방법(대결 2000. 3. 17. 99마3754), 가처분해 제신청서가 위조되었다고 주장하는 가처분채권자가 법원의 촉탁에 의하여 말소된 가처분기입 등기의 말소회복을 구하는 방법(대판 2000. 3. 24. 99다27149, 대결 2010. 3. 4. 2009그 250), 집행권원상의 청구권을 양도한 채권자가 집행력이 소멸한 이행권고결정서의 정본에 기하여 강제집행절차에 나아간 경우의 불복방법(대판 2008. 2. 1. 2005다23889), 집행법원이 최고가매수신고인임이 명백한 사람에 대하여 특별한 사정없이 매각허가여부의 결정을 하지 아니하는 경우의 불복방법(대결 2008. 12. 29. 2008그205), 배당기일부터 1주 이내에 청구 이의의 소재기사실 증명서류와 그 소에 기한 집행정지재판의 정본이 제출되지 않았는데도 집행법원이 채권자에 대한 배당을 중지하였다가 청구이의의 소의 결과에 따라 추가배당절차를 밟는 경우 채권자의 불복방법(다만 채권자가 집행에 관한 이의신청 대신 추가배당표에 대하여 배당이의의 소를 하고 당초 배당표대로 배당을 실시해 달라는 취지로 배당이의의 소를 제기하였다면, 배당이의의 소를 심리하는 법원은 소송경제상 당초 배당표대로 채권자에게 배당을 실시할 것을 명한다는 의미에서 추가배당표상 배당할 금액을 당초 배당표와 동일하게 배당하는 것으로 추가배당표를 경정하여야 한다. 대판 2011. 5. 26. 2011다16592), 집행취소서류의 제출에 의하여 집행처분을 취소하는 재판에 대한 불복방법(대결 2011. 11. 10. 2011마1482)은 모두 집행에 관한 이의신청이다.

한편 민사집행법의 명문 또는 해석상 불복할 수 없는 재판에 대하여는 즉시항고나 집행에 관한 이의신청을 할 수 없고, 특별항고만 할 수 있다. 즉시항고에 따른 집행정지 등의 재판(민집 15조 9항), 집행에 관한 이의신청에 따른 집행정지 등의 재판(민집 16조 2항, 15조 9항 유추), 집행에 관한 이의신청에 대한 재판 중 이의신청을 기각한 경우나 민사집행법 17조 1항 등에 해당하지 않아 즉시항고의 대상이 되지 않는 경우(대결 2005. 10. 31. 2005그 87, 대결 2008. 5. 22. 2008그90 등), 집행문부여 거절처분에 대한 이의신청을 기각한 재판(대결 2011. 6. 13. 2011그57 등), 집행문부여에 대한 이의신청에 관한 재판(대결 1995. 5. 13. 94마2132, 대결 2008. 8. 21. 2007그49 등), 집행문부여에 대한 이의의 소·청구이의의 소·제3자의이의 소에 따른 집행정지 등의 재판(민집 46조 2항, 48조 3항, 민소 500조 3항 유추, 대결 2001. 2. 28. 2001그4 등), 이송의 재판(민집 182조 2항, 민집규 119조 2항), 압류금지 물건·채권의 범위를 정하는 신청과 그 범위를 변경하는 신청에 따른 집행정지 등의 재판(민집 196조 5항, 민집 246조 4항), 양도명령·매각명령·관리명령 등의 특별현금화명령 신청을 기각하는 결정(대결 2011. 1. 14. 2010그185) 등이 이에 해당한다.

나. 집행관의 집행처분, 그 밖에 집행관이 지킬 집행절차

집행관의 집행처분은 집행관이 집행기관으로서 하는 법률효과를 수반하는 처분을 말한다. 따라서 집행관이 집행기관이 되는 유체동산에 대한 금전집행이나 물건 인도청구의 집행 등에서 집행관이 한 처분에 대하여는 집행에 관한 이의신청으로 불복할 수 있다.

집행관이 집행법원의 보조기관으로서 하는 직무행위, 예를 들어 현황조사(민집 85조), 경매의 실시(민집 107조)라든가, 또는 집행관 외 집행법원의 보조기관이 하는 직무행위, 예를 들어 대체집행의 수권결정에 기하여 채권자나 채권자의 위임을 받은 제3자가 실시하는 대체적 작위행위(민집 260조, 민 389조) 등도 이의신청의 대상이 되는가에 관하여는 긍정설과 부정설로 견해가 나뉘어 있다.

집행관이 지킬 집행절차는 집행관의 집행처분 외에 집행관이 집행에서 지켜야 하는 절차를 말한다. 예를 들어, 법률효과를 수반하지 않는 집행관의 사실행위(민집 7조 2항에 의하여 행하는 저항배제를 위한 원조 등)가 위법인 경우, 집행관이 집행기록의 열람을 거부하는 경우 등이 이에 해당한다.

다. 집행관의 집행위임의 거부, 집행행위의 지체 및 수수료

집행관이 집행을 위임받기를 거부하거나 집행행위를 지체하는 경우에 집행에 관한 이의를 신청할 수 있다(민집 16조 3항 전단). 이는 집행행위를 고의로 하지 않는 경우뿐만 아니라 태만으로 지연하는 경우도 포함한다. 집행법원이 집행처분을 지체하는 경우에도 집행에 관한 이의신청을 할 수 있는가에 관하여는 긍정설과 부정설이 있다. 106

집행관이 계산한 수수료에 대하여 다툼이 있는 경우에도 집행에 관한 이의를 신청할 수 있다(민집 16조 3항 후단).

3. 이의사유

원칙적으로 집행법원 또는 집행관이 스스로 조사·판단할 수 있는 사항에 한한다. 주로 절차상의 사유가 되겠지만, 집행법원 또는 집행관이 스스로 조사·판단할 수 있는 사항이라면 실체상의 사유(민집 40조, 41조)도 예외적으로 이의사유가 된다. 집행기관은 집행을 개시함에 있어 집행대상이 채무자에게 속하는지를 스스로 조사·판단하여야 하고, 이는 건물철거의 대체집행에서 수권결정에 기초하여 작위의 실시를 위임받은 집행관이 실제 철거를 실시하는 경우에도 마찬가지이므로, 집행관이 변경된 현재의 건축주 명의인이 채무자

와 다르다는 이유만으로 철거대상 미등기 건물이 채무자에게 속하는 것이 아니라고 판단하여 철거를 실시하지 않았다면, 이는 집행관이 지킬 집행절차를 위반하여 집행을 위임받기를 거부하거나 집행행위를 지체한 경우에 해당하여 채권자는 집행에 관한 이의신청으로 구제받을 수 있다(대결 2014. 6. 3. 2013그336).

집행권원의 내용인 청구권의 부존재, 소멸 또는 외관상의 명의나 점유가 실체상의 권리와 부합하지 않는 것을 다투는 것은 청구이의의 소나 제3자이의의 소로 하여야 한다.

4. 이의의 절차

가. 관할

- 107 집행법원이 관할법원이 된다. 집행관의 집행행위에 대하여는 그 집행절차를 실시할 곳이나 실시한 곳을 관할하는 지방법원이 집행법원으로 된다(민집 3조 1항). 그 중 토지관할은 전속 관할이다(민집 21조). 집행법원 이외의 법원에 이의가 신청된 때에는 민사소송법 34조를 준용하여 관할법원에 이송하여야 한다(민집 23조 1항). 따라서 집행에 관한 이의신청만이 인정되고 즉시항고가 허용되지 아니하는 경우 이에 대하여 불복하면서 제출한 서면의 제목이 '즉시항고장'이고 그 끝부분에 '항고법원 귀중'이라고 기재되어 있다 하더라도 이를 집행에 관한 이의신청으로 보아 처리하여야 할 것이므로, 집행법원이 그 불복사건을 항고법원으로 보냈다면 항고법원으로서의 그 사건기록을 집행법원으로 보내 집행법원으로 하여금 그 신청의 당부에 대하여 판단하도록 하여야 한다(대결 2000. 3. 17. 99마3754).

나. 당사자적격

이의신청은 집행기관의 위법한 처분에 대하여 불복의 이익이 있는 집행채권자, 집행채무자 및 제3자가 할 수 있다. 장차 경매절차에서 응찰할 예정이라는 사유만으로는 그 경매절차에 관하여 법률상 이해관계를 가진다고 할 수 없어 집행에 관한 이의를 신청할 적격이 없다(대결 1999. 11. 17. 99마2551). 신청권자의 채권자가 신청권자를 대위하여 집행에 관한 이의신청을 할 수도 없다.

이의절차는 편면적인 것이므로 상대방이 없으나, 실무에서는 그 재판에 대하여 대립하는 이해관계가 있는 사람을 상대방으로 정하여 심리하고 결정문에도 그를 상대방을 표시하여 주는 예가 많다. 그러나 집행관이 집행위임이나 실시를 거부하여 이의신청에 이른 때에도 집행관은 상대방으로 되지 않는다.

다. 신청과 접수

(1) 신청의 방식

이의신청은 집행법원이 실시하는 기일에 출석하여 하는 경우가 아니면 서면으로 하여야 한다(민집규 15조 1항). 기일에 이의신청을 하는 경우, 예를 들어 집행법원이 실시하는 기일인 배당기일 등에서 이의신청을 하는 경우에는 법원사무관등의 참여 아래 직접 법원 108에 신청하는 것이므로 말로 하는 신청도 허용된다. 이 경우 참여한 법원사무관등은 기일조서에 신청취지와 이유의 요지를 기재하여야 한다(민소 161조 3항 준용). 매각기일 등은 집행관이 실시하는 기일이므로 여기서 말하는 기일에 들어가지 않는다.

이 이의신청에 상대방의 표시는 필요하지 않으나, 심리에서는 대립하는 이해관계인을 상대방으로 정하여 관여시키는 경우가 많음은 앞서 본 바와 같다.

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 5항 4호, 재민 91-1). 구술신청의 경우에는 조서에 인지를 붙인다(인지 1조).

이의신청을 하는 때에는 이의의 이유를 구체적으로 밝혀야 한다(민집규 15조 2항). 이는 절차지연 등의 의도로 정당한 이유 없이 집행에 관한 이의신청을 하는 것을 막기 위한 것이다. 따라서 이의의 이유를 밝히지 아니하는 때에는 바로 신청을 각하할 수 있다. 다만 집행에 관한 이의신청은 즉시항고에 비하여 간이한 불복방법이므로 즉시항고이유의 기재방법(민집규 13조)과 같은 정도를 요구하는 것은 아니고 그 이유를 구체적으로 밝히는 것으로 충분하다. 그리고 집행에 관한 이의신청에는 즉시항고에서의 항고이유서 제출강제주의(민집 15조 3항)와 같은 규정이 없으므로 이의재판 당시까지 이유를 추가하는 것이 가능하다.

(2) 신청의 시기

이의신청은 원칙적으로 집행이 개시된 뒤에 하여야 한다. 다만 집행관이 집행의 위임을 거부하는 경우에는 집행개시와 상관없이 이의를 신청할 수 있다.

집행절차가 종료한 후에는 이의신청이 허용되지 않는다(대결 1979. 10. 29. 79마150, 대결 1996. 7. 16. 95마1505). 다만 집행관의 수수료 계산에 대한 이의신청은 집행종료 후에도 할 수 있다.

(3) 접수

신청서가 제출되면 민사집행사건(사건부호 '타기')으로 접수하여 사건번호와 사건명을 부여하고, 집행사건부에 전산입력한 후 별도기록으로 만든다(재민 91-1).

109 라. 심리

(1) 집행법원의 재판은 변론 없이 할 수 있다(민집 3조 2항). 집행법원은 집행처분을 하는 데 필요한 때에는 이해관계인, 그 밖의 참고인을 심문할 수 있다(민집규 2조). 증명의 정도에 관하여서는 특별한 규정이 없으므로 소명으로는 부족하고 증명이 있어야 한다.

(2) 이의의 재판에서도 당사자가 신청하지 아니한 사항이나 신청의 범위를 넘어서는 재판할 수 없다.

마. 재판

(1) 재판의 형식과 고지

집행에 관한 이의신청에 대한 재판은 결정으로 한다. 변론을 거친 경우에도 같다. 이의신청에 정당한 이유가 있다고 인정한 때에는 그 집행처분을 허가하지 않는다고 또는 집행관에게 특정한 집행을 하여야 한다는 취지를 선언한다. 이의신청이 부적법하다고 인정한 때에는 그 신청을 각하할 것이고, 정당한 이유가 없다고 인정한 때에는 기각한다. 집행불허의 재판이 선언되면 신청인은 그 재판의 정본을 집행기관에 제출하여 집행처분의 취소를 구할 수 있다(민집 49조 1호, 50조).

집행에 관한 이의신청에 대한 재판은 원칙적으로 신청인에게만 고지하면 족하지만(민집규 7조 2항), 그 중 상대방이 즉시항고할 수 있는 재판과 민사집행법 16조 2항의 잠정처분 재판 및 잠정처분이 이루어진 경우의 집행에 관한 이의신청에 대한 재판은 신청인과 상대방에게 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 2호, 4호).

(2) 재판의 효력과 주문 기재례

집행에 관한 이의신청에 대한 재판은 결정으로 이루어지므로 기판력이 없다. 그러나 동일 사유에 기하여 다시 집행에 관한 이의신청을 하는 것은 정당한 이익이 없어 허용되지 않는다고 할 것이다.

신청을 인용하는 주문 기재례를 유형별로 예시하면 다음과 같다.

110 (가) 집행관에게 집행의 실시를 명하는 경우

“○○법원 소속 집행관 ○○○은 위 법원 20○○타인○○ 부동산인도명령 사건의 집행력 있는 결정 정본에 기한 신청인의 위임에 따라 별지목록 기재 건물에 대한 인도집행을 실시하라.”는 등으로 집행관의 소속, 이름, 집행권원, 집행목적물 및 집행행위의 내용을 특정하여 표시하여야 한다.

(나) 집행관에게 집행위임을 명하는 경우

“○○법원 소속 집행관 ○○○은 위 법원 20○○나○○ ○○ 사건의 집행력 있는 화해조서정본에 기한 신청인의 위임을 받아들여 상대방에 대한 강제집행을 실시하라.”는 등으로 표시한다. 이 경우는 집행위임을 명할 뿐 구체적인 집행행위를 명하는 것이 아니므로 집행 목적물과 집행처분을 특정하지 않아도 무방하다.

(다) 집행행위를 취소 또는 불허하는 경우

“신청인과 상대방 사이의 ○○법원 20○○카단○○ 유체동산가압류 사건의 결정 정본에 기한 상대방의 위임에 따라 위 법원 소속 집행관이 별지 목록 기재의 동산에 대하여 실시한 가압류집행은 이를 취소한다.” 등으로 위 (가)항과 같은 4가지 사항을 표시하면 될 것이다. 불허하는 경우에는 말미 부분에 “이를 허가하지 아니한다.”라고 선언한다.

(라) 강제집행절차 중 일부를 취소하는 경우

“○○법원 소속 집행관 ○○○이 신청인과 ○○○ 사이의 위 법원 20○○가단○○ ○○ 사건의 판결정본에 기하여 20○○. ○○. ○○. 실시한 별지 목록 기재 동산에 대한 경매절차 중 그 매각대금을 배당한 처분을 취소한다. 신청인의 나머지 신청을 기각한다.”는 등의 표현으로 취소되는 부분을 특정하여야 한다.

(마) 집행관에게 특정한 집행을 명하는 경우

“○○법원 소속 집행관 ○○○은 ○○법무법인 작성의 20○○년 증제○○호 집행력 있는 공정증서 정본에 기한 신청인의 위임에 따라 20○○. ○○. ○○. 압류한 별지 목록 기재 동산에 대하여 경매집행을 실시하라.” 등으로 구체적인 집행행위를 표시할 것이다.

(3) 불복방법 등

111

집행에 관한 이의신청에 대한 재판 중 ① 집행절차를 취소하는 결정, ② 집행절차를 취소한 집행관의 처분에 대한 이의신청을 기각·각하하는 결정, ③ 집행관에게 집행절차의 취소를 명하는 결정 및 ④ 경매개시결정에 대한 이의신청에 관한 재판에 대하여만 즉시항고를 할 수 있다(민집 17조 1항, 86조 3항). 위 ①, ②, ③의 재판에 대하여 즉시항고를 인정한 것은 이들 재판으로 하나의 집행절차가 목적을 달성하지 못한 채 종료하게 됨으로써 이 단계에서 항고를 인정하지 않으면 상급심의 판단을 받을 기회를 상실하기 때문이고(다만 집행관은 상급기관인 집행법원의 감독을 받는 지위에 있으므로 위 재판에 대하여 불복할 수 없고 이에 따라야 할 뿐이다), 위 ④의 재판에 대하여 즉시항고를 인정한 것은 경매개시결정이 이해관계인에게 미치는 영향이 매우 크기 때문이다.

집행에 관한 이의신청에 대한 재판 중 그 밖의 경우, 즉 이의신청을 기각한 경우나 위 ①, ②, ③, ④의 재판에 해당하지 않는 경우에 대하여는 불복이 허용되지 아니하여 특별항고만이 가능하다(대결 2005. 10. 31. 2005그87, 대결 2008. 5. 22. 2008그90 등). 이 경우에 재도의 고안을 할 수 없다.

한편 집행에 관한 이의신청에 대한 재판 중 위 ①, ②, ③의 재판은 확정되어야 효력을 가지지만(민집 17조 2항), 위 ④의 재판(다만 경매개시결정에 대한 이의신청을 받아들여 집행절차를 취소하는 결정은 위 ①의 재판에 해당한다)이나 나머지 재판은 즉시 효력을 가진다.

바. 잠정처분

민사집행은 집행에 관한 이의신청에 의하여 정지되지 않는다. 그러나 법원은 그 이의신청에 대한 재판에 앞서 채무자에게 담보를 제공하게 하거나 제공하게 하지 아니하고 집행을 일시정지하도록 명하거나 채권자에게 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명하는 등 잠정처분을 할 수 있다(민집 16조 2항). 이 잠정처분의 재판은 민사집행의 신청인 112 과 상대방에게 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 4호).

명문의 규정은 없으나 민사집행법 15조 9항을 유추하여 잠정처분의 재판에 대하여는 불복할 수 없다고 할 것이므로, 특별항고만이 가능하다.

한편 잠정처분의 재판은 집행법원이 직권으로 하는 것이고 당사자에게 신청권이 있는 것이 아니므로, 당사자의 잠정처분신청은 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없다. 따라서 즉시항고에서의 경우와 마찬가지로 법원은 이 신청에 대하여는 재판을 할 필요가 없고, 설령 법원이 이 신청을 거부하는 재판을 하였다고 하여도 불복이 허용될 수 없으므로 그에 대한 불복은 특별항고도 부적법하다(대결 2016. 7. 26. 2016그80 참조).

사. 사법보좌관의 처분에 대한 이의신청

사법보좌관규칙 3조 2호는 사법보좌관이 집행에 관한 이의신청의 대상이 되는 처분을 하였을 경우 이해관계인이 민사집행법 16조 1항에 따라 이의신청을 하고, 이에 대한 재판은 판사가 담당하도록 하였다. 이러한 절차는 해당 처분을 판사가 한 경우와 원칙적으로 같다.

제6장 집행비용

제1절 의의

집행비용은 민사집행에 필요한 비용, 즉 민사집행의 준비 및 실시를 위하여 필요한 비용을 말한다.

집행비용은 민사집행절차에 드는 비용을 말하므로, 의사의 진술을 명하는 판결에 기하여 등기를 하는 경우의 등기비용은 여기서 말하는 집행비용이 아니고, 소송비용액 확정결정의 신청비용도 집행비용이 아니다.

채권자대위권 행사로 인한 비용은 강제집행을 직접 목적으로 하여 지출된 것이 아니므로 집행비용이 아니다. 또한, 사해행위취소소송에 의하여 사해행위의 목적이 된 재산이 채무자의 책임재산으로 원상회복되고 그에 대한 강제집행절차가 진행되었더라도, 사해행위취소소송을 위하여 지출한 소송비용, 사해행위취소를 원인으로 한 말소등기청구권 보전을 위한 부동산처분금지처분 비용, 사해행위로 마쳐진 소유권이전등기의 말소등기 비용은 집행비용에 해당하지 않는다(대판 2011. 2. 10. 2010다79565).

제2절 집행비용의 종류

집행비용에는 민사집행의 준비 및 실시를 위하여 필요한 비용이 포함된다(대판 2011. 2. 10. 2010다79565). 집행준비비용은 집행의 준비에 필요한 비용, 즉 집행실시 이전에 집행개시를 위하여 필요한 비용이고, 집행실시비용은 집행신청 이후에 채권자와 집행기관이 집행절차를 수행하기 위하여 필요한 비용이다.

또 집행비용은 재판상의 비용과 당사자비용으로 나눌 수 있다. 재판상의 비용은 채권자

가 인지, 현금 또는 우표 등으로 법원이나 집행관에게 납부하여야 하는 비용을 말하고, 당사자비용은 채권자가 법원이나 집행관 이외의 사람에게 직접 지출한 비용을 말한다.

따라서 집행준비비용과 집행실시비용에 각각 재판상의 비용과 당사자비용이 있을 수 있다.

집행비용은 또 공익비용과 그 밖의 집행비용으로 나눌 수 있다. 공익비용은 채권자 전원의 공동이익을 위하여 한 행위에 든 비용으로 법률상 절차비용이라 일컬어지며(민집 102조 1항) 모든 채권에 우선하여 변상받을 수 있다.

공익비용과 그 밖의 집행비용은 지출된 비용의 성질에 따라 구별할 수밖에 없다. 민사집행절차를 진행하는 데에 든 비용은 모든 채권자의 공동이익을 위한 것이므로 공익비용이지만, 특정채권자에게만 이익이 된 것은 공익비용이 아니다. 전자의 예로는 집행개시의 요건을 충족시키기 위한 집행권원의 송달비용이나 집행문부여비용, 강제집행신청비용, 압류비용, 현금화비용, 배당비용 등이 있고, 후자의 예로는 배당요구나 채권계산서 제출에 든 비용 등이 있다.

공익비용이 아닌 그 밖의 집행비용은 그 채권자가 배당받을 본래의 채권과 동순위로 배당받는다.

제3절 집행비용의 범위

1. 집행준비비용

(가) 집행준비비용은 민사집행을 준비하기 위하여 지출한 비용이다.

- 115 민사소송비용법은 집행준비비용에 관하여 직접적인 규정을 두고 있지 않으나, 채권자가 집행신청을 위하여 지출한 비용을 모두 채권자가 부담하게 하는 것은 집행신청을 하지 않을 수 없게 만든 채무자와의 형평상 불합리하고 또 집행준비비용을 별도로 청구하도록 하는 것도 합리적이 아니므로 이러한 비용도 필요한 한도 내에서 집행비용이 되는 것으로 보아야 한다. 집행개시의 요건을 충족시키기 위한 집행권원의 송달비용, 집행문부여비용이나 증명서교부비용 등이 이에 속한다.

이 이외에도 집행문부여신청이나 집행신청을 하기 위하여 법원에 출석하는 데에 든 비용, 가집행의 선고가 있는 판결에 의한 담보공탁을 하기 위하여 공탁기관에 왕복한 여비,

공탁서 서기로 등도 집행준비비용으로 된다. 집행권원인 재판의 송달비용은 협의의 소송 비용인 동시에 집행비용이라고 하는 것이 통설이다. 그러나 집행권원이 된 화해조서, 조정조서, 공정증서의 송달에 관한 비용은 오직 집행비용으로만 취급된다.

(나) 판결, 화해조서, 인낙조서, 조정조서 등의 집행권원 성립 이전에 채권자가 지출한 비용, 담보권설정에 관한 비용은 집행준비비용에 포함되지 않는다. 집행신청과 직접 관련 없는 비용, 예를 들어 집행이 담보제공에 달린 경우의 담보금 조달비용은 집행준비비용에 속하지 않는다. 반대급부제공을 위한 비용도 채권자가 당연히 이행할 의무를 이행한 것에 지나지 않으므로 강제집행을 위한 비용이라 할 수 없다. 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판에 대하여 집행판결을 얻는 데 든 비용이나 중재판정에 대하여 집행결정을 얻는 데 든 비용도 외국재판이나 중재판정 그 자체만으로는 집행권원이 될 수 없고 집행판결이나 집행결정을 얻어야 비로소 집행권원이 될 수 있으므로(민집 26조 1항, 중재법 37조 2항) 집행비용이라기보다는 집행권원을 얻기 위한 소송비용으로 보는 것이 일반적이다.

(다) 집행준비비용은 채권자가 실제로 지출한 경우에 한하여 인정되어야 하므로, 집행기록상 그 지출이 명백하지 아니한 경우에는 원칙적으로 채권자가 그 지출을 소명하지 아니하면 집행비용으로서 추심할 수 없다. 집행준비비용은 집행의 개시를 전제로 하는 것이므로 집행이 개시되지 않는 한 채권자가 부담하여야 하며 채무자가 부담할 집행비용으로 되지 않는다. 따라서 집행개시 전에 집행신청을 취하하거나 신청이 기각된 경우에는 집행비용으로서 고려될 여지가 없다.

116

2. 집행실시비용

(가) 집행실시비용은 집행신청 이후에 채권자와 집행기관이 집행절차의 수행을 위하여 필요한 비용이다. 집행절차는 법률의 규정에 따라 진행되므로 집행실시비용은 집행기록상 명백하다.

집행신청의 수수료(첨용인지), 서기로, 집행관수수료, 압류물의 보존비용(민집 198조 2항), 통지·공고의 비용, 증인·감정인·관리인의 일당·보수 등이 이에 해당한다.

기본 되는 집행에 부수되는 집행, 예를 들어 증권의 점유(민집 233조), 채권증서의 인도(민집 234조), 자동차의 인도(민집규 125조) 등의 집행에 필요한 비용은 그 기본 되는 집행을 집행실시비용으로 된다.

이 이외에도 유체동산집행에서 채권자의 매각최고비용(민집 216조), 압류의 경합에서 추가압류비용(민집 215조), 채권집행에서 제3채무자의 진술을 구하는 신청에 관한 비용(민집 237조), 전화가입원부 등록사항 증명에 필요한 비용, 부동산집행에서 채권자에 대한 경매개시결정정보 송달비용(단, 특별송달의 경우는 제외), 채권자가 배당기일에 출석한 경우의 출석일당 및 여비, 과잉경매의 경우 매각불허가 된 부동산에 관한 절차비용 등은 집행비용으로 된다.

신청채권자 이외의 사람이 지출한 것이라도 집행비용으로 되는 것이 있다. 예를 들어, 압류채권자 이외 채권자의 채권신고, 배당요구, 채권계산서 제출(민집 84조, 88조, 217조, 247조, 253조 등)에 필요한 비용 등이 이에 해당한다.

- 117 (나) 그러나 집행의 실시와 직접 관련 없는 비용, 예를 들어 집행을 계기로 하여 제기된 이의나 소의 비용(즉시항고, 집행에 관한 이의신청, 집행문부여 등에 관한 이의신청, 집행문부여의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소, 청구이의의 소, 제3자의이의 소 등에 관한 비용)은 이들 독립된 절차의 소송비용이지 집행비용이 아니다. 또 민사집행의 실시를 위하여 필요한 비용이더라도 국가가 부담하여야 할 비용, 예를 들어 통지서의 작성, 물건명세서 사본의 작성 등에 든 비용은 민사집행의 비용에 포함되지 않는다.

집행절차가 수계된 경우에, 일반승계의 경우에는 수계 전의 집행비용이 승계인에게 승계되며 특히 상속인이 수인인 경우에는 각 그 상속분에 응하여 분할하여 승계될 것이나, 특정승계의 경우(예를 들어, 압류채권자에 대하여 채권을 가지는 사람이 압류채권자의 채무자에 대한 채권을 압류하여 전부명령을 받은 후에 압류채권자의 승계인으로서의 집행문을 부여받아 강제경매를 승계하는 경우)에는 집행비용채권에 관하여서까지 승계를 한 것이 아니므로 원칙적으로 승계 전의 비용에 대하여는 승계인이 배당을 받을 수 없다. 다만 기본채권의 양수인이 승계집행문을 받아 강제경매를 수계한 경우에 양수인이 집행비용채권도 양수받은 때에는 당연히 수계 전의 비용도 승계인에게 승계된다. 수계 전의 집행비용을 승계인에게 배당하지 아니하는 경우에는 피승계인이 배당받을 수 있다. 강제경매에서 이중의 경매신청이 있어 다시 경매절차의 개시결정을 한 경우에 후의 경매신청에 소요된 비용(예를 들어, 신청서 서기로, 첩용인지대 등)은 공익비용으로서의 집행비용으로 되지 아니하나, 앞의 사건 경매신청의 취하 또는 경매절차의 취소로 말미암아 뒤의 사건에 의하여 절차가 진행된 때에는 뒤의 사건에서의 경매신청비용 이하 모든 비용이 그 경매절차를 위하여 필요한 집행비용(공익비용, 이하 같다)으로 되어 모두 그 집행에 의하여 변상받는다. 다만 앞의 사건에서 현황조사가 종료되어 그것이 그대로 인용되는 경우에는 뒤의 경매

신청인이 한 위 조사신청비용은 집행비용으로 되지 않는다.

(다) 가압류·가처분의 집행에 대하여는 강제집행에 관한 규정이 준용되므로(민집 291조, 301조) 가압류·가처분의 집행에 든 비용은 집행비용으로 된다. 단체 임원 등의 직무대행자를 선임하는 가처분의 경우, 채권자가 예납한 금전에서 지급된 직무대행자의 보수는 가처분의 집행에 드는 비용에 해당하므로 민사집행법 53조 1항에 정해진 집행비용으로 보아야 한다(대결 2011. 4. 28. 2011마197). 보전집행의 필요비용은 채권자가 가압류 또는 다툼의 대상에 관한 가처분의 집행 후 집행권원을 얻어 본집행을 하게 되면 본집행의 집행비용 일부로 된다. 118

3. 필요한 비용

민사집행의 비용 중 집행에 필요한 것만이 집행비용으로 되고(민집 18조 1항, 53조 1항), 현실적으로 지출한 것이라도 필요가 없는 것은 집행비용이 아니다.

채권자의 부주의로 하지 않아도 되거나 쓸모없는 절차를 행하는 데에 든 비용은 집행에 필요한 비용이라고 할 수 없으므로 집행비용이 아니다. 예를 들어, 정해진 요건을 제대로 갖추지 못하여 신청을 보정한 경우 그 보정에 든 비용이라든가, 채무자의 주소를 오기하였기 때문에 집행관이 불필요한 여비를 지출한 경우 그 여비 등은 필요한 비용이라 할 수 없으며, 비용의 예납을 촉구하는 데 든 비용이라든가 매각기일 변경신청서의 서기로도 필요한 비용이라 할 수 없다. 채권자가 할 의무가 있는 행위 또는 할 것으로 예정되어 있는 행위 이외의 행위를 채권자가 임의로 하더라도 그 비용은 집행을 위하여 필요한 비용이라 할 수 없으므로 집행비용으로 되지 않는다. 가령 출석요구를 받거나 출석이 필요한 기일 이외의 일시, 예를 들어 부동산 매각기일, 매각결정기일에 법원에 임의로 출석하더라도 그 비용은 집행비용으로 되지 않는다.

이 점과 관련하여 문제 되는 것이 부동산 등의 인도청구 집행에서 채권자가 집행현장에 출석하는 데에 든 비용이다. 이 경우에는 채권자나 그 대리인이 집행장소에 출석한 때에 한하여 집행할 수 있으므로 채권자 측의 출석이 필요적이기는 하나, 강제집행에 의하지 않고 부동산 등을 인도받더라도 그 부동산 등의 소재지에 나가야 하므로 강제집행을 위하여 특히 필요한 비용이라 할 수 없다는 이유로 집행비용으로 보지 않는 것이 일반적이다. 119

결과적으로 아무런 소용없이 끝난 행위에 지출된 비용은 집행비용이 아니다. 예를 들어, 배당요구 종기 이후에 채권계산서를 제출(민집 84조 4항)하는 경우 이에 든 비용은 집행비

용으로 되지 않는다.

인용하면 당연히 집행비용으로 되는 부수적 신청(예를 들어, 민집 83조 3항의 부동산에 대한 침해행위를 방지하기 위한 조치의 신청)에 관한 것일지라도 그것이 각하된 때에는 그 신청에 들어간 비용이 집행비용에 해당되지 않음은 말할 것도 없다.

또한, 민사집행이 절차 도중에 신청취하나 절차취소로 종료된 때에는 그때까지의 절차와 그 준비에 든 비용은 결국 필요 없는 것이 되어 집행비용으로 되지 않는다(민집규 77조 참조). 다만 당해 목적재산에 관한 후행 사건이 존재하여 절차가 속행되는 경우에 취하한 채권자 등이 지출한 비용이 속행절차에서 그대로 유용하게 이용되는 행위나 절차에 관한 것이라면 후행 사건의 집행비용으로 된다고 보는 것이 지배적이다.

제4절 집행비용의 예납

1. 예납

가. 총설

집행비용은 종국적으로는 채무자(소유자)의 부담으로 되지만(민집 53조 1항, 275조), 집행절차 내에서 회수할 수 없는 경우도 있기 때문에 신청인으로 하여금 일정한 소요경비 120 를 미리 내게 한 후 배당 등의 절차 단계에서 이를 청산하도록 하고 있다.

채권자가 예납하여야 할 비용을 미리 내지 아니하면, 집행관은 위임에 응하지 아니하거나 사무를 행하지 아니할 수 있고(집행관수수료규칙 25조) 집행법원은 결정으로 신청을 각하하거나 집행절차를 취소할 수 있다(민집 18조 2항). 다만 집행채권자가 소송구조를 받은 때(민소 129조, 집행관수수료규칙 25조 1항 단서) 또는 대체집행에서 채권자의 신청에 의하여 법원이 미리 채무자에게 집행비용을 지급할 것을 명한 때(민집 260조 2항)에는 예납할 필요가 없다.

나. 집행관이 집행기관인 경우

(1) 개설

집행관은 집행관수수료규칙 25조에 의하여 수수료 기타 비용의 계산액을 예납시킬 수

있다. 예납제도는 집행관의 편의를 위한 것이므로 집행관이 불이익을 감수하고 예납 없이 집행을 실시할 수도 있다.

(2) 예납하여야 할 비용 및 예납액

예납하여야 할 비용은 위임한 집행사건에 관하여 집행관이 지급받을 수수료(집행관수수료규칙 2조 이하)와 그 집행사건을 수행하는 데에 소요되는 비용(집행관수수료규칙 20조)이다.

집행관은 채권자가 예납하여야 할 수수료와 비용의 계산액을 집행관수수료규칙에 따라 결정한다. 계산액은 그 집행사건이 통상 절차에 따라 진행될 것을 예상하여 그 사건 종료까지에 통상적으로 필요한 수수료와 비용액을 산출한다.

예를 들어, 동산에 대한 강제집행에서는 압류수수료, 경매수수료, 압류통지비용, 공고비용, 평가비용, 집행관의 여비 등으로 계산액을 산출할 것이다.

사무를 개시한 후 예납금이 부족한 때에 집행관은 추가예납을 시킬 수 있다(집행관수수료규칙 25조 2항). 한편 집행절차 중 생기는 특별한 비용, 예를 들어 압류물 보존을 위한 특별처분에 필요한 비용 등은 집행위임시의 예납액에 포함되는 것이 아니고 그 필요 시에 예납시키면 된다(민집 198조 2항).

121

(3) 예납의무자

예납의무자는 민사집행(강제집행, 담보권의 실행 등을 위한 동산경매)이나 가압류·가처분의 집행을 신청한 사람이다.

벌금, 과료, 추징금 등 재산형이나 과태료의 집행에서도 수수료, 비용의 계산액을 납부시킬 수 있다.

(4) 예납절차, 예납의 효과, 예납금의 출금

(가) 집행관은 강제집행신청 또는 담보권의 실행 등을 위한 동산경매신청이 있으면 당해 사건의 집행에서 지급받아야 할 수수료와 비용의 계산액을 산정하여 신청인에 대하여 위 계산액을 상당한 기간 내에 예납할 것을 고지하고, 예납금을 납부하고자 하는 사람에게 정보처리시스템에 의한 집행관 사무처리지침(행정예규 1201호) 별지 [제3호 서식]의 납부서를 교부하여 예납금 납부당사자가 취급점(해당 은행 타 취급점 포함)에 직접 납부하게 하는 것이 원칙이다.

취급점(해당 은행 타 취급점 포함)이 납부자로부터 예납금 등을 납부받았을 때에는 납부

자에게 영수증을 교부하고, 그 내역을 지체 없이 집행관사무소로 전송한다.

122

[양식] 정보처리시스템에 의한 집행관 사무처리지침 별지 [제3호 서식]

납부서(은행제출용)			
		실명확인	(인)
집행관사무소		사건번호	
납부금종류		은행관리번호	
납부금액			
납부자	성명	주민등록번호 (사업자등록번호)	
	전화번호	우편번호	
	주소		
	잔액환급계좌	(예금주 :)	
대리인	성명	주민등록번호 (사업자등록번호)	
	전화번호	우편번호	
	주소		
위 금액을 납부합니다. 2000. 0. 0. 납부자 (인) 대리인 (인)			
1. 납부시 실명확인을 위하여 필요하오니 납부자의 주민등록증(대리인이 납부시에는 대리인의 주민등록증)을 지참하시기 바랍니다. 2. 집행관이 매각대금 및 매수신고보증금 납부시, 『납부자』란에는 매수인 또는 매수신고보증금 납부자의 성명 등을 기재하고 『납부당사자 기명날인』란에는 대리인 집행관 ○○○라고 표시하며, 아래에 경매물건 소유자의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 주소를 기재하여야 합니다. 3. 납부는 법원별 지정 취급점 또는 해당 은행 타취급점에 납부하시기 바랍니다.			
성명		주민등록번호 (사업자등록번호)	
주소			

123

(나) 집행 중에 예납금이 부족하게 되면 다시 그 부족분을 추가로 예납시킬 수 있다. 추납하지 아니하는 때에 집행관은 사무를 행하지 아니할 수 있고(집행관수수료규칙 25조 2항) 이미 행한 집행을 취소할 수도 있다 할 것이다.

그러나 유체동산에 대한 금전집행에서 경매가 신속히 실시되어 매각대금으로부터 즉시 수수료와 비용을 확실하게 지급받을 수 있다고 예측되는 때에는 추가예납명령에 응하지 않는다는 이유만으로 이미 행한 압류를 해제하는 것은 부당하다.

‘동산집행사건에 있어서 집행관 수수료 기타 비용의 예납범위 등에 관한 지침(행정예규 297호)’에 의하면, 집행관이 동산집행사건을 위임받을 때에는 원칙적으로 그 사건의 집행 완료시까지의 전체 수수료 등의 액을 계산하여 신청인으로 하여금 이를 전부 예납하게 하여야 하고(2조 본문), 다만 ‘집행관 집행미제사건 등 처리지침(행정예규 496호)’ 1. 가.의 특약사항에 대하여 승낙한 신청인이 일부 예납의 의사표시를 할 경우에는 그 수수료 등의 일부만을 예납하게 할 수 있으며(2조 단서), 이와 같이 수수료 등의 일부만을 예납한 신청인이 압류 후 1개월이 경과하여도 나머지 수수료 등을 추가예납하지 아니할 경우에 집행관은 행정예규 496호의 규정에 의하여 지체 없이 신청인에게 추가예납을 촉구하는 통지를 하는 등의 절차를 취하여야 한다(4조). 신청인이 이러한 예납통지와 예납 재통지를 받고도 수수료 기타 비용의 계산액을 예납하지 아니하면 집행관은 강제집행 위임을 취한 것으로 보아 지체 없이 집행권원을 신청인에게 반송하고 기록은 보존절차를 취하여야 한다[행정예규 496호 2. 가. (3)].

(다) 사무가 종료한 때에 집행관은 지체 없이 예납금의 정산을 하여 예납금에 잔액이 있으면 신청인에게 잔액을 반환하여야 하고, 예납자의 청구가 있는 때에는 정산의 내용을 명시한 서면을 교부하여야 한다(집행관수수료규칙 25조의2).

집행관의 예납금 관리, 정산 및 잔액환급의 절차는 ‘정보처리시스템에 의한 집행관 사무 처리지침(행정예규 1201호)’에서 정한 절차에 의하는데, 집행사건이 종결되면 집행관은 지체 없이 수수료 기타 비용 등 예납금을 사용할 사항이 있는지 여부를 확인한 후 종결사실을 전산시스템에 등록하고, 종결된 사건에 대한 예납금의 환급은 대표집행관이 승인하여 그 승인 시 환급 내역을 취급점으로 전송하며, 예납자가 계좌입금신청을 한 경우에는 그 계좌로 환급금을 입금하고, 예납자가 직접 환급청구를 한 경우에는 대표집행관이 출급지시서를 예납자에게 교부하여 이를 취급점에 제출하게 한다.

124

다. 법원이 집행기관인 경우

(1) 개설

집행법원에 민사집행신청(강제집행, 담보권의 실행 등을 위한 경매신청) 또는 가압류·가처분의 집행을 신청하는 때에 채권자는 집행에 필요한 비용으로서 법원이 정하는 금액

을 미리 내야 하고, 법원이 부족한 비용을 미리 내라고 명하는 때에도 채권자는 그 금액을 미리 내야 한다(민집 18조 1항, 291조, 301조).

(2) 예납하여야 할 비용 및 예납액

(가) 신청인이 미리 내야 할 비용은 법원이 집행절차를 수행하기 위하여 필요로 하는 재판상의 비용 중 법원이 지급할 비용, 예를 들어 서류의 송달 또는 송부비용, 공고비용, 현황조사수수료, 평가료, 매각수수료 등 집행개시 후의 해당금을 지급하는 데 필요한 비용이다.

따라서 집행개시 후의 당사자비용과 집행개시 전의 비용은 예납의 대상이 되지 아니하며 각종 신청 시의 수수료는 인지 첩부의 방법으로 납부되기 때문에 역시 예납의 대상이 되지 않는다.

부동산 강제경매개시결정등기, 담보권의 실행 등을 위한 경매개시결정등기, 가처분의 등기 등의 등록면허세는 현금을 국고수납대행기관에 납부하고 등록면허세 영수필확인서를 법원에 제출해야 하므로 예납의 대상이 되지 않는다.

(나) 집행비용은 그 비용이 필요한 개개의 행위 시마다 개별적으로 예납시키는 것이 원칙이나 이렇게 하는 것은 오히려 집행절차의 원활한 진행을 해하므로 미리 통상의 절차에 따른 집행종료 시까지의 비용 계산액을 일괄하여 예납시킨다.

125 집행절차의 종류별로 일정한 예납기준에 따라서 예납액을 결정하는 것이 바람직하다.

부동산경매신청사건에서 경매신청인에게 예납시킬 매각수수료의 예납액은 개별공시지가(토지), 개별주택공시가격(일반주택), 공동주택공시가격(아파트), 기준시가(상업용 건물, 오피스텔) 등을 기준으로 하여 집행관수수료규칙 16조 소정의 매각수수료 산정방법에 의하여 산정하며, 집행관수수료규칙 17조 2항 각 호의 사유로 경매되지 못한 때에 지급할 매각수수료예납금은 동 조항에 정한 금액의 5회분으로 한다(재민 79-5 3조).

송달료의 납부는 대법원장이 지정하는 각 법원별 해당 송달료 수납은행에 우표가 아닌 현금으로 납부하여야 하나, 다만 법원장은 사건 수, 법원과 송달료수납은행과의 거리 등을 감안하여 당사자 1인당 송달료납부기준이 2회 이하인 사건의 전부 또는 일부에 대하여 법원 내규로써 송달료를 우표로도 납부할 수 있도록 정할 수 있다(재일 87-4 8조 1항, 2항). 2012. 12. 3.부터 시행된 개정 송달료규칙은 납부인이 송달료를 현금으로 납부하는 경우 이를 수납은행 또는 송달료납부대행기관의 인터넷 홈페이지 등에서 송달료납부대행기관을 통하여 신용카드·직불카드 등으로도 납부할 수 있도록 하였다(송달료규칙 3조의2

1항, 재일 87-4 8조의2). 부동산등경매사건(타경)의 경우 예납할 송달료는 “(신청서상의 이해관계인 수+3)×10회분으로 산출한 금액”을 기준으로 한다(재일 87-4 7조, [별표 1]).

송달료 예납액에 관한 상세한 것은 법원실무제요 민사소송Ⅱ 제6장 제2절 6. 나. 적용 대상사건 및 납부기준 및 재일 87-4 참조.

(3) 예납의무자

민사집행을 신청한 채권자가 예납의무자이다(민집 18조 1항). 단, 소송구조를 받은 사람은 예납의무를 부담하지 않는다.

국가, 지방자치단체나 그 밖의 공공단체가 신청하는 경우에도 예납의무가 있다.

(4) 예납절차

126

(가) 송달료 이외의 비용예납절차

사건을 법원에 접수하기 전에 미리 비용을 납부한 경우, 취급점은 납부자에게 법원보관금취급규칙의 별지(이하 ‘별지’) [제3호 서식](전산양식 A1253)의 법원보관금 영수필통지서와 별지 [제4호 서식](전산양식 A1252)의 법원보관금 영수증서를 교부하고(보관금규 10조 1항), 당사자는 취급점으로부터 받은 별지 [제3호 서식](전산양식 A1253)의 법원보관금 영수필통지서를 접수서류에 첨부하여 법원에 제출하여야 한다(보관금규 9조 4항).

비용을 미리 납부하지 않고 사건이 접수된 경우에는 사건담임 법원사무관등은 담임법관(사법보좌관)으로부터 납부할 금액을 확인받은 후 이를 납부할 당사자에게 적당한 방법으로 고지하여야 하고(보관금규 9조 1항), 비용을 예납하여야 할 당사자는 별지 [제1호 서식](전산양식 A1250)의 법원보관금 납부서를 작성하여 현금(금융기관 발행의 자기앞수표 포함)으로 취급점에 납부하여야 한다(보관금규 9조 2항). 다만 매각대금을 납부하게 하는 때와 비용을 미리 내야 할 사람이 비용을 납부하지 아니 하는 때에 사건담임 법원사무관등은 담임법관(사법보좌관)으로부터 별지 [제2호 서식](전산양식 A1254)의 법원보관금 납부명령서를 발부받아 이를 당사자에게 교부하여 법원보관금을 취급점에 납부하게 하여야 한다(보관금규 9조 3항).

취급점이 납부자로부터 법원보관금을 납부받았을 때에는 납부자에게 별지 [제4호 서식](전산양식 A1252)의 법원보관금 영수증서를 교부하고(보관금규 10조 1항), 지체 없이 출납공무원과 사건담임자 및 계약담당공무원에게 그 수납내역을 전송하여야 한다(보관금규 10조 2항).

사건담임 법원사무관등은 취급점으로부터 전송된 수납내역을 확인한 후 사건번호, 과코

드 및 재판부번호 등 필요한 사항을 전산등록하여야 하고(보관금규 11조), 출납공무원은
 127 취급점으로부터 전송된 수납내역에 대하여 별지 [제5호 서식](전산양식 A1255)의 법원보
 관금 수불명세서와 별지 [제6호 서식](전산양식 A1256)의 법원보관금 일제표를 각 출력하
 여 이를 확인하여야 한다(보관금규 12조).

(나) 송달료 예납절차

일반적인 송달료의 예납절차와 송달료규칙이 적용되는 경우의 송달료납부절차에 관하
 여는 법원실무제요 민사소송[I] 제6장 제2절 6. 송달료의 예납 및 재일 87-4 참조.

(다) 예납기간

민사집행법은 예납기간에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 그러나 당사자가 비용
 을 예납하지 아니한 경우에는 신청을 각하하거나 이미 실시한 집행절차를 취소할 수 있음
 (민집 18조 2항)에 비추어 예납기간을 정하여 예납명령을 하여야 한다. 실무상으로는 5일
 내지 7일의 기간을 정하여 예납을 명하는 것이 통례로 되어 있다. 그러나 이 기간은 재정
 기간이므로 이를 연장할 수 있다 할 것이다(민소 172조). 한편 예납명령의 고지방법에 관
 하여는 아무런 제한이 없으나 고지의 일시를 명확히 하기 위하여 재판의 등본을 송달하는
 방법으로 하는 것이 타당하다. 실무상으로 법원에 나온 당사자에게는 위에서 본 납부명령
 서 별지 [제2호 서식](전산양식 A1254)를 교부하고 영수증을 받는 방법이 주로 이용되고
 있다.

129

[전산양식 A1254] 별지 [제2호 서식] 법원보관금 납부명령서

법원보관금 납부명령서				
법원코드		과코드	재판부번호	
사 건 번 호				물건번호
납 부 금 액		금 원정 (₩)		
보 관 금 종 류				
납 부 년 월 일		년 월 일		
납 부 자	성명		전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)		우편번호	
	주소			
대 리 인	성명		전화	
	주민등록번호 (사업자등록번호)		우편번호	
	주소			
위의 보관금을 납부하시기 바랍니다.				
2000. 0. 0.				
○○지방법원 ○○지원				
판사(사법보좌관)[계약담당공무원] (인)				
※ 법원보관금 납부 시 실명확인을 위하여 필요하오니 주민등록증을 지참하시기 바랍니다.				

130

[전산양식 A1253] 별지 [제3호 서식] 법원보관금영수필통지서(법원제출용)

법원보관금 영수필통지서(법원제출용)				
은행번호 :				
법 원 명				
사 건 번 호		물 건 번 호		
납 부 금 액			보관금 종류	
납부자 성명		주민등록번호(사업자등록번호)		
납부자 주소			전 화 번 호	
잔 액 환 급 계 좌 번 호	은행	지점	예 금 주	
	계 좌 번 호			
위의 보관금이 납부되었음을 알려드립니다.				
년 월 일				
은행 지점				

[전산양식 A1252] 별지 [제4호 서식] 법원보관금영수증서(납부자용)

법원보관금 영수증서(납부자용)

은행번호 :

법 원 명			
사 건 번 호		물 건 번 호	
납 부 금 액		보관금 종류	
납부자 성명	주민등록번호(사업자등록번호)		
납부자 주소		전 화 번 호	
잔 액 환 급 계 좌 번 호	은행	지점	예 금 주
	계 좌 번 호		

위의 금액을 보관금으로 영수합니다.

년 일 일

은행 지점

[전산양식 A1255] 별지 [제5호 서식] 법원보관금 수불명세서

131

법원보관금 수불명세서

2000. O. O.

사 건 번 호	진 행 번 호	입 금 액	지 급 액	비 고
합 계				

(주) 진행번호란이 '이자'로 명기된 경우는 경매사건 관련 '법원보관금 이자조회서'의 이자금액에서 지급된 배당금·집행비용등임

[전산양식 A1256] 별지 [제6호 서식] 법원보관금 일계표

법원보관금 일계표			
2000. O. O.			
법원보관금		건수	금액
개 별 계 좌	전 일 잔 액		
	금 일 입 금 액		
	금일 일괄계좌 에서 전 환 액		
	금 일 지 급 액		
	금 일 잔 액		
	(이 자 지 급 액)	()	()
입 괄 계 좌	전 일 잔 액		
	금일 지급액 (국고수표지급액)		
	금일 개별계좌 로의 전 환 액		
	금 일 잔 액		
잔액합계(개별+입괄)			

(주) '이자지급액'은 '법원보관금 수불명세서'의 진행번호란이 '이자'로 명기된 경우의 지급액임

132 (5) 예납금의 출금

(가) 집행법원은 예납금으로부터 그 본래의 사용 목적인 행위에 소요된 비용을 지급한다.

(나) 집행법원의 담임법관(사법보좌관)은 현황조사수수료, 각종의 감정료, 감정인의 여비·일당, 공고의 신문게재료 등에 관하여는 조사·감정·게재 등의 행위가 완료된 후(조사보고서, 감정서 등이 법원에 제출된 후) 집행관·감정인·한국언론진흥재단 등의 청구에 의하여 별지 [제7호 서식](전산양식 A1257)의 법원보관금 출금명령서를 출금청구자에게 교부하되, 동시에 여러 건의 출금청구가 있는 경우에는 별지 [제9호 서식]의 법원보관금 출금명세서를 함께 교부하고(보관금규 13조 1항), 사건담임 법원사무관등은 위 출금명령서 사본을 기록에 편철하며, 출금청구자는 교부받은 출금명령서를 출납공무원에게 제출하여야 한다(보관금규 13조 2항). 출금명령서를 제출받은 출납공무원은 출금지시사항을 취급점에 전송하고 출금청구자에게 별지 [제8호 서식](전산양식 A1258)의 출금지시서를 교부

하여 이를 취급점에 제출하게 하되, 동시에 여러 건의 출급청구가 있는 경우에는 별지 [제 9호 서식]의 법원보관금 출급명세서를 함께 교부한다(보관금규 13조 3항). 출급지시를 받은 취급점은 출급청구자의 청구에 따라 법원보관금을 지급하고 그 지급내역을 즉시 사건담임 법원사무관등 및 출납공무원에게 전송하여야 한다(보관금규 16조).

출급청구자가 별지 [제11호 서식](전산양식 A1261)의 법원보관금 계좌입금신청서에 의하여 법원보관금을 자기의 비용으로 자신의 예금계좌에 입금하여 줄 것을 신청한 경우에는 법원보관금을 신고된 예금계좌에 입금하여 지급하는데(보관금규 15조 1항, 2항), 이 경우 사건담임 법원사무관등은 그 계좌번호를 전산등록하여야 한다(보관금규 15조 3항).

법원서기관, 법원사무관, 등기사무관, 법원주사, 등기주사, 법원주사보 또는 등기주사보가 집행관의 직무를 행한 경우의 수수료는 국고수입으로 되므로(집행관법 19조 3항), 이 경우에는 수입에 편입하는 절차를 취하여야 한다.

(다) 일반적인 송달료의 출급절차와 송달료규칙이 적용되는 경우의 송달료 처리에 관하여는 법원실무제요 민사소송[I] 제6장 제2절 6. 송달료의 예납 및 재일 87-4 참조. 133

(라) 사건이 종결된 후 예납금 중 잔액이 있을 때에는 당사자의 환급청구를 기다릴 것 없이 지체 없이 환부하여야 한다. 송달료 이외의 예납금에 관한 환부절차는 법원보관금취급규칙 21조에서 정한 절차에 의한다.

일반적인 송달료의 잔액 반환과 송달료규칙이 적용되는 경우의 송달료 잔액 환급에 관하여는 법원실무제요 민사소송[I] 제6장 제2절 6. 송달료의 예납 및 재일 87-4 참조.

(6) 예납불이행의 효과

채권자가 예납할 비용을 미리 내지 아니한 때에 집행법원은 결정으로 신청을 각하하거나 집행절차를 취소할 수 있다(민집 18조 2항). 그러나 예납에 응하지 않더라도 집행절차를 진행할 수 있는 때, 예를 들어 부동산 경매에서 예상외로 목적물이 고가로 매각되었기 때문에 이미 예납받은 비용만으로는 집행관에게 지급할 매각수수료에 부족이 생겨 추가 예납을 명하였으나 채권자가 이에 응하지 않은 경우에는 매각대금 중에서 이를 지급하고 배당 등의 절차를 진행함이 상당하다 할 것이다. 또 예납기간이 경과하였다 하더라도 신청을 각하하거나 집행절차를 취소하기 전에 예납한 때에는 신청을 각하하거나 절차를 취소할 수 없다고 할 것이다. 신청을 각하하거나 절차를 취소하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 18조 3항).

채권자가 즉시항고를 하면서 집행법원이 명한 예납액을 납부한 경우에 그 예납의 효과를

어떻게 볼 것인가에 관하여는 이론상 긍정설과 부정설로 견해가 나뉘어 있고 아직 이에 관한 직접적인 판례는 없으나, 소장각하명령에 관하여 판례가 재판장의 소장심사권에 의하여 소장각하명령이 있었을 경우에는 즉시항고를 하고 흠결을 보정하였더라도 그 각하명령을 취소할 수 없다(대결 2007. 5. 3. 2007마264, 대결 1996. 1. 12. 95두61)고 함으로써 후설을 취하고 있으므로 집행절차의 경우에도 이와 궤를 같이하여 처리함이 옳을 것이다.

2. 예납의 유예

가. 예납의 유예를 받는 사람

소송구조를 받은 사람(민소 128조)이 민사집행신청을 하는 경우에는 집행비용예납의 유예를 받고(민소 129조 1항 1호) 국고에서 지급한다. 소송구조는 구조결정을 받은 사람에 한하여 효력이 있으므로(민소 130조 1항) 피구조자의 승계인이 민사집행신청을 한 경우에는 승계인이 새로이 구조결정을 받아야 예납의 유예를 받을 수 있다. 구조의 재판은 제1심뿐만 아니라 상소심에서도 할 수 있기 때문에 어느 심급의 구조결정이 민사집행에 효력을 미치는가에 관하여는 어느 심급의 구조결정도 무방하다는 견해와 집행권원인 판결을 한 법원에 의한 구조결정이 있어야 한다는 견해가 있다.

판결절차와 별도로 집행절차에서만 구조신청을 할 수도 있다(소송절차에서의 구조 없이 집행단계에서만 이루어지는 구조를 소송구조와 대비하여 ‘집행구조’라고 한다). 구조신청의 관할법원에 관하여는 집행법원이 구조의 재판을 한다는 견해(통설)와 제1심의 수소법원이 할 것이라는 견해가 있는데, 민사소송법에 “소송구조에 대한 재판은 소송기록을 보관하고 있는 법원이 한다.”라는 규정이 있지만(민소 128조 3항) 위 규정을 민사집행에 준용할 때 위 규정상의 ‘소송기록’을 ‘집행기록’으로 보아야 할 것이므로(집행관에게 하는 집행신청사건의 경우에도 동일하게 해석할 수 있을 것이다), 집행법원이 관할법원이라는 견해가 타당하다고 생각된다. 한편 위 견해의 대립은 강제집행의 경우에 한정된 것이고, 담보권 등의 실행을 위한 경매신청사건(형식적 경매 포함)에는 수소법원의 개념이 없으므로 집행법원이 관할법원으로 될 수밖에 없을 것이다. 집행법원이 구조신청을 기각한 경우 신청인은 즉시항고를 할 수 있다(민소 133조 준용).

135 구조의 결정은 장래를 향하여 효력이 발생하는 것이 원칙이나, 신청 시로 소급시킬 수도 있다. 이 경우에 신청인이 이미 예납하였으면 이를 반환하여야 할 것이다.

나. 예납유예를 받을 비용의 범위

피구조자는 민사집행에 필요한 재판비용, 변호사·집행관의 보수와 체당금의 지급이 유예된다(민소 129조 1항 본문). 다만 법원이 상당한 이유가 있어서 이 중 일부에 대한 소송구조를 한 경우에는 그 일부에 대하여만 예납이 유예된다(민소 129조 1항 단서).

법원이 집행기관인 경우에는 인지, 송달료, 집행관의 수수료, 여비, 감정인의 여비, 보수 등의 예납이 유예된다. 송달료, 감정인의 보수, 공고게재비 등은 국고에서 대납지급되고, 집행관의 보수·체당금은 지급이 유예되며 나중에 채무자로부터 추심되지 아니한 경우에는 강제집행절차가 종료된 후 소송구조를 한 법원이 보수를 받을 집행관의 신청을 받아 집행관수수료규칙을 참조하여 결정으로 정한 금액을 국고에서 지급하게 된다(민소규 26조). 경매개시결정등기의 등록면허세는 재판비용에 준하여 국고에서 대납된다.

집행준비를 위한 재판비용, 예를 들어 집행문부여신청서 첩용인지, 송달증명신청서 첩용인지, 승계집행문 송달비용 등에도 구조의 효력이 미친다.

집행관이 집행기관인 경우에는 수수료와 그 직무집행에 필요한 비용에 관하여 예납이 유예된다.

그러나 당사자비용, 예를 들어 서류의 서기로, 제출비용, 등기사항증명서 교부수수료 등은 구조의 대상이 되지 않는다.

다. 예납유예의 취소

집행절차 진행 중에 피구조자가 비용을 납입할 자금능력이 있음이 판명되거나 그 자금 136
능력이 있게 된 때에 집행법원은 직권 또는 이해관계인의 신청에 의하여 언제든지 구조를 취소하고 예납을 유예한 비용의 납입을 명할 수 있다(민소 131조 준용).

유예비용납입결정[수봉결정(收捧決定)]은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력이 있으므로(민비 12조 1항) 구체적으로 비용액을 결정하여야 한다.

라. 유예비용의 추심

(1) 예납이 유예된 비용은 당연히 집행비용이 되어 채무자의 부담으로 되므로 별도로 비용의 지급을 명하는 재판을 할 필요 없이 강제집행과 동시에 추심할 수 있다(민집 53조 1항).

그러나 채권에 대한 집행에서 전부 또는 추심명령을 발하는 경우에 국고가 지급받아야 할 재판비용을 채권압류명령에 표시하여 채권자에게 전부하거나 추심권을 부여하는 것은

적당하지 아니하므로 이러한 경우에는 민사소송비용법 12조에 의하여 채무자에 대한 비용부결정을 하여 이를 집행권원으로 하여 추심하여야 한다.

대체집행·간접강제에서 국고가 지급받아야 할 재판비용의 추심도 위와 같은 방법으로 한다.

(2) 집행관이 동산 또는 부동산 등의 인도집행을 한 경우의 수수료와 비용은 기본이 되는 강제집행절차에서 추심할 수 없으므로 집행관은 비용액의 확정결정신청을 하여 이 결정을 집행권원으로 하여 강제집행을 할 수 있다(민소 132조 준용).

(3) 집행법원이 유예비용을 추심한 때에는 수입편입절차를 취하여야 한다.

제5절 집행비용의 부담

(1) 강제집행에 필요한 비용은 종국적으로 채무자가 부담하고 그 집행에 의하여 우선적으로 변상을 받는다(민집 53조 1항). 즉, 강제집행의 준비와 실시를 위한 모든 비용은 채권자가 우선 지출하여야 하나 그 중 강제집행에 필요한 부분은 집행비용이 되어 비용부담의 재판이 필요하지 않고 채무자의 부담으로 되는 것이다.

집행에 불필요한 비용은 채권자가 부담한다. 예를 들어, 채권자가 집행신청을 하면서 부주의로 채무자의 주소를 오인하여 집행관이 불필요한 여비를 지출한 경우 그 여비는 채권자가 부담한다.

(2) 채권자가 집행준비를 위하여 지출한 비용은 강제집행을 개시하지 아니하면 집행비용으로 고려될 여지가 없다.

집행이 개시된 다음에 지출한 비용이라 하더라도 집행신청이 취하되거나 집행절차가 취소되는 등 집행 본래의 목적인 청구권의 실현을 보지 못하고 종료된 경우에 그 비용은 채권자가 부담한다. 채권자가 집행신청의 일부를 취하하거나 집행절차의 일부가 취소된 경우 등에서 그 일부의 집행에 소요된 비용도 채권자가 부담하고 집행비용으로 되지 않는다.

(3) 집행당사자 이외의 제3자가 집행비용을 부담하는 경우도 있다. 예를 들어, 부동산경매절차에서 전의 매수인이 재매각기일의 3일 이전까지 대금, 그 지급기한이 지난 뒤부터 지급일까지의 대금에 대한 대법원규칙이 정하는 이율에 따른 지연이자와 절차비용을 지급하여 재매각절차를 취소하는 경우가 있다(민집 138조 3항).

담보권 실행 등을 위한 경매에도 민사집행법 53조가 준용되나(민집 275조), 민사집행법

53조의 문언 자체에 의하더라도 “그 집행에 의하여 우선적으로 변상”을 받도록 되어 있음에 비추어 볼 때 실체법상의 비용부담자는 별론으로 하더라도(민 473조 참조) 그 경매절차에서는 경매목적물의 귀속주체인 소유자를 경매비용의 부담자로 보아야 할 것이다.

제6절 집행비용의 추심

138

1. 추심의 방법

가. 강제집행비용의 추심

(1) 개설

강제집행비용은 그 추심을 위하여 별도의 집행권원 없이 본래의 강제집행에 의하여 우선적으로 변상을 받는다(민집 53조 1항). 따라서 본래의 강제집행이 금전채권에 기초한 것일 경우에는 해당 집행절차에서 변상받을 수 있다.

그러나 인도집행과 같은 금전채권 외의 채권에 기초한 것일 경우에는 해당 집행절차에서 집행비용을 변상받을 길이 없으므로 집행비용을 추심하기 위해서는 그에 관하여 별도로 집행비용액 확정결정을 받아 이를 집행권원으로 하여 따로 금전집행을 할 수밖에 없다(민집규 24조). 부동산인도 강제집행의 집행비용에 대한 집행법원의 집행비용액 확정결정이 없는 경우에 그 집행비용은 위 부동산 인도 강제집행의 집행권원인 확정판결에 기한 강제경매(금전집행)절차에서도 추심할 수 없다(대판 2006. 10. 12. 2004재다818).

본래의 집행이 금전채권에 기초한 것일지라도 그 집행절차에서 변상을 받지 못하였을 경우에는 별도로 집행법원에 집행비용액 확정결정의 신청을 하여 그 결정을 집행권원으로 하여 금전집행을 한다(민집규 24조 1항).

동시에 추심할 경우에 일부 누락한 집행비용에 관하여는 본래의 강제집행이 완결 전이면 집행기관이 계산을 정정하여 추심할 수 있으나 집행이 완료되어 집행권원의 정본을 채무자에게 반환한 후에는 집행비용액 확정결정을 받아서 추심할 수밖에 없다. 집행비용을 별소로써 청구하는 것은 소의 이익이 없으므로 허용되지 않는다(대판 1979. 2. 27. 78다1820, 대결 1996. 8. 21. 96그8).

집행개시 후 본안의 청구가 변제나 그 밖의 사유로 소멸된 때라도 집행비용채권이 남아

- 139 있으면 본안의 집행권원에 기하여 집행비용 추심을 위해서만 강제집행을 속행할 수 있고 (대판 1989. 9. 26. 89다2356, 대판 1992. 4. 10. 91다41620 참조), 채무자가 변상하여야 할 집행비용이 상환되지 아니한 이상 해당 집행권원의 집행력 전부의 배제를 구할 수는 없다(대판 2012. 5. 24. 2011다105195).

(2) 부동산에 대한 강제집행

(가) 강제경매에서 집행비용은 집행법원이 부동산을 매각한 매각대금의 배당시에 계산하여 채권자에게 상환한다. 집행법원은 집행기록과 채권자가 제출한 채권계산서를 근거로 하여 직권으로 집행비용을 계산한다.

집행비용은 어떠한 채권보다도 우선하여 추심된다. 그러나 이미 경매개시결정이 있는 부동산에 대하여 다시 강제경매신청을 한 경우에는 종전의 매각절차가 취소되거나 경매신청이 취하되지 않는 한 후의 경매신청비용은 모든 채권자의 공동이익을 위한 공익비용이 아니므로 우선적으로 배당받을 수는 없다. 공익비용이 아닌 그 밖의 집행비용은 이를 지출한 채권자가 배당받을 본래의 채권과 같은 순위로 배당받는다.

(나) 강제관리에서 집행비용은 관리인이 제3자로부터 추심한 수익금으로부터 지급받는다. 집행비용 중 강제관리신청비용, 강제관리개시결정등기를 위한 등록면허세 등 협의의 집행비용은 최우선적으로 변상을 받게 되나(민집 53조), 관리인에 대한 보수 등 관리비용은 그 부동산이 부담하는 조세, 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 지급받는다(민집 169조 1항). 그러나 관리인이 협의의 집행비용을 알 수 없으므로, 집행법원은 그 집행비용을 수익에서 공제할 수 있도록 집행비용액을 계산하여 배당 전에 관리인에게 이를 통지하여야 하며, 채권자로서도 집행비용의 추심을 위하여 강제관리개시결정서에 집행비용의 표시가 있으면 그 결정정본을 제출하고 그 표시가 없으면 집행법원의 담임 법원사무관등으로부터 증명서를 교부받아 이를 제출하는 등의 방법으로 집행비용액을 스스로 증명하는 것이 좋다.

- 여러 명의 채권자가 경합하여 수익금을 배당하는 경우 채권자들 사이에 배당협약이 이루어지지 못하면 관리인은 집행법원이 작성한 배당표에 의하여 각 채권자에게 수익금을 배당하여야 하므로(민집 169조 4항) 채권자가 추심할 집행비용은 집행법원이 배당표 작성시에 계산하고 관리인으로부터 지급받는다.

이미 강제관리개시결정이 있는 부동산에 대하여 다시 강제관리신청이 있는 경우에 그 신청비용의 처리에 관하여는 전술한 강제경매의 경우와 같다.

(3) 선박 등에 대한 강제집행

등기할 수 있는 선박이나 등록된 자동차, 건설기계 및 '자동차 등 특정동산 저당법'의 적용을 받는 소형선박·항공기·경량항공기에 대한 강제집행은 원칙적으로 부동산 강제경매에 관한 규정에 의하므로(민집 172조, 187조, 민집규 106조, 108조, 130조), 집행비용의 추심도 전술한 강제경매의 경우와 마찬가지로이다.

(4) 유체동산에 대한 강제집행

(가) 이 경우에는 압류물의 매각대금으로부터 채권자의 청구채권과 함께 집행비용을 추심할 수 있다(민집 188조 2항, 207조). 압류물이 내국통화인 때에는 이로부터 직접 집행비용을 추심할 수 있다(민집 201조).

(나) 이중압류가 된 경우에, 후행 압류에 소요된 비용 중 더 압류할 물건이 있어 추가압류를 하는 데 소요된 부분은 공익비용으로서 매각대금으로부터 우선변제받을 수 있다. 그러나 후행 압류에 소요된 비용 중 이를 제외한 부분과 관련하여서는, 부동산집행과 같이 선행 압류에 의하여 절차를 진행한다는 명문의 규정(민집 87조)이 없어 여러 압류가 경합된 상태에서 절차가 진행되는 것으로 보아야 하더라도, 집행비용에 관한 한 선행 압류의 압류채권자가 지출한 비용만이 공익비용에 해당하여 우선변제의 대상이 되고, 다른 압류채권자가 지출한 비용은 집행채권의 원금, 이자와 함께 그 채권자의 채권금액에 산입되어 배당될 수 있을 뿐이라고 보아야 한다.

(5) 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행

(가) 금전채권에 대한 강제집행에서는 집행기관이 현실의 현금화에 관여하지 아니하므로 채권압류명령에 집행비용이 표시되지 않는 한 채권자는 전부명령에 의하여 제3채무자 141로부터 집행비용의 변제를 받을 수 없으며 또한 추심명령에 의하여 제3채무자로부터 압류채권을 수령하여 집행비용의 변제에 충당할 수 없다.

실무상으로는 채권압류명령신청서에 집행비용의 기재가 없으면 그대로 접수하여 채권압류명령 및 전부 또는 추심명령이 발하여지므로 채권자가 청구채권과 함께 집행비용을 추심하려면 채권압류명령신청서에 집행비용을 청구하는 취지를 명기할 필요가 있다(그러나 이에 대하여는, 채권에 대한 집행과 같은 경우에는 그 집행절차에서 집행비용을 동시에 추심할 수 없으므로 반드시 집행비용액 확정결정을 거칠 필요가 있다고 하는 견해도 있다).

이와 같이 채권압류명령에 집행비용이 명시되어 있는 경우에 그 현금화방법이 전부명령이면 이에 의하여 채권자는 집행비용을 우선적으로 전부받는 방법으로 집행비용을 추심한

다. 채권압류명령과 다른 시기에 전부명령신청을 하는 경우에는 전부명령신청비용을 채권압류명령에 표시할 수 없으므로 전부명령신청서에 그 비용을 기재하면 전부명령에 이를 부기하여 변제받을 수 있다.

그 현금화방법이 추심명령이면 압류채권자는 제3채무자로부터 직접 추심한 금액이나 (배당에 참가한 다른 채권자가 없는 경우) 배당절차에서 받은 배당금으로 집행비용과 청구채권에 변제충당한다.

추심명령 신청을 압류명령 신청과 다른 시기에 한 경우 추심명령 신청비용의 추심은 전부명령의 경우와 같다.

채권압류명령신청서 등에 기재를 누락한 집행비용은 후일 집행비용액 확정결정신청의 대상이 된다.

한편 금전채권이 조건부, 기한부이거나 반대 의무의 이행과 관련되어 있거나 그 밖의 이유로 추심하기 곤란하여 양도명령, 매각명령, 관리명령, 그 밖의 적당한 방법으로 현금화가 행해지는 경우(민집 241조)에 집행비용의 추심은 후술하는 (마)의 방법으로 한다.

(나) 지시채권의 압류(민집 233조)나 채권증서 인도(민집 234조)의 경우에 집행비용은 전부명령 또는 추심명령에 부기하여 추심할 수 있고 후일 집행비용액 확정결정으로 추심할 수도 있다.

- 142 (다) 유체동산에 관한 청구권에 대한 집행(민집 243조)의 경우에 집행관은 임의 또는 강제에 의하여 압류의 목적물을 점유하고 현금화절차를 실시한 후 매각대금을 집행법원에 인계하여 집행법원이 그 배당절차를 행하므로 집행비용은 집행법원이 직권으로 계산하여야 한다. 따라서 압류신청서에 집행비용의 기재가 없어도 채권자는 그 추심을 받을 수 있다.

(라) 부동산에 관한 인도청구권 또는 부동산에 관한 권리이전청구권에 대한 집행(민집 244조)의 경우에는 그 부동산이 보관인에게 인도되거나 채무자 명의의 등기가 되면 그 현금화절차는 부동산에 대한 강제집행방법에 의하므로 그 집행비용은 강제경매 또는 강제관리에서 추심할 수 있다. 그러나 그 집행비용은 강제경매 또는 강제관리의 집행비용 계산시 명백하지 아니하므로 채권자는 집행비용액을 소명할 필요가 있다.

(마) 금전채권, 유체물의 인도나 권리이전의 청구권 이외의 재산권에 대한 강제집행에는 민사집행법 223조 이하의 규정이 준용되므로(민집 251조 1항) 그 현금화는 집행법원이 권리의 종류·성질에 따라서 추심명령이나 전부명령(민집 229조) 또는 양도명령·매각명령·관리명령 등의 특별현금화명령(민집 241조)에 의하여 행하여진다. 따라서 추심명령이나 전부명령 또는 전부명령과 같은 취지의 양도명령 등에 의하여 현금화가 되는 경우에

채권자가 집행비용을 추심하기 위해서는 압류명령 또는 추심·전부·양도명령신청서에 집행비용을 구체적으로 표시하여야 한다. 다만 실무상으로 양도명령의 경우에는 압류명령신청서나 양도명령신청서에 기재가 없더라도 감정료에 한해서는 그 추심을 허용하고 있다.

그러나 매각명령이나 임의매각 등의 현금화방법에 의할 경우에는 집행법원이 직권으로 집행비용을 계산하여야 한다.

(6) 동산의 배당절차

(가) 유체동산에 대한 강제집행에서 여러 명의 채권자가 경합하여 집행법원의 배당절차가 행하여지는 경우(민집 252조 1호, 222조)에 채권자는 채권자가 제출한 채권계산서와 집행기록에 의하여 집행법원이 계산한 집행비용을 우선 배당받아 이를 추심한다. 143

(나) 채권압류 및 추심명령에 의한 집행에서 민사집행법 236조의 규정에 의하여 추심채권자가 공탁하거나 민사집행법 248조의 규정에 의하여 제3채무자가 공탁하는 경우에도 법원이 배당절차를 실시하게 되므로(민집 252조 2호), 이 절차에서 집행비용을 추심한다.

(7) 금전채권 외의 채권에 기초한 강제집행

(가) 물건 인도청구의 집행에서 그 집행비용 상환청구권은 금전채권이므로, 물건의 인도 집행절차에서 집행비용을 추심할 수 없고 그 추심을 위해서는 별도로 집행비용액 확정결정을 받아 이를 집행권원으로 하여 채무자의 다른 재산에 대하여 금전집행을 할 수밖에 없음은 앞에서 본 바와 같다.

(나) 대체집행에서는 채권자가 제1심 수소법원에 채무자에 갈음하여 하는 행위에 필요한 비용을 미리 지급할 것을 채무자에게 명하는 결정을 신청하여 그 결정에 의하여 채무자로부터 비용을 추심할 수 있다(민집 260조 2항). 채무자가 이 결정에 의한 비용을 임의로 지급하지 아니하는 경우에 채권자는 이 결정에 집행문을 부여받아 채무자의 재산에 대하여 금전집행을 하여 이를 추심할 수 있다.

그러나 이 결정에 의하여 추심할 수 있는 비용은 채권자가 채무자에 갈음하여 하는 행위에 필요한 비용, 예를 들어 건물철거를 제3자로 하여금 실시하게 하는 경우의 비용(집행관 수수료, 노무자의 수당, 물건의 운반비용 등) 또는 광고의 게재료 등에 한하며 그 이외의 비용, 예를 들어 대체집행신청의 서기로, 첩용인지대, 제출비용 등은 포함되지 아니하므로, 채권자가 이러한 비용을 추심하기 위해서는 별도로 집행비용액 확정결정을 받아 이에 기하여 채무자의 다른 재산에 대하여 금전집행을 하여야 한다. 채권자가 민사집행법 260조 2항의 결정에 의하여 추심한 비용액이 실제로 필요한 비용보다 적은 경우에 그 초과비

용에 대하여도 집행비용액 확정결정을 얻어 이에 기하여 금전집행을 하여 추심할 수 있다 (민집 260조 2항 단서).

- 144 (다) 간접강제에서 채권자가 그 신청에 필요한 집행비용을 추심하기 위해서는 집행비용액 확정결정을 받아 그 결정을 집행권원으로 하여 금전집행을 하여야 한다.

(8) 보전집행비용의 추심

(가) 가압류의 집행에 관하여는 원칙적으로 강제집행에 관한 규정이 준용되므로(민집 291조) 가압류의 집행비용은 본안의 강제집행과 동시에 추심할 수 있다. 다만 가압류의 집행비용은 본집행의 기록에 명백히 나타나지 아니하므로 채권자가 그 비용을 본집행과 동시에 추심하기 위해서는 소명을 하여야 한다.

본집행과 별도로 가압류집행비용을 추심하기 위해서는 집행비용액 확정결정을 받아야 한다.

부동산 강제경매절차 등에서 가압류채권자에게 배당이 된 경우에는 가압류채권이 확정된 후에 지급되는 그 배당금에서 가압류집행비용이 제1순위로 변제된다.

(나) 가처분집행비용의 추심은 가처분의 집행방법에 따라 다르다. 금전지급을 명하는 가처분의 집행은 본집행의 규정에 따라 금전집행이 실시되므로 집행비용도 그 금전집행절차에서 추심할 수 있다.

그 이외 집행방법의 경우, 예를 들어 물건의 인도 등 급부를 명하는 경우, 작위·부작위를 명하는 경우, 부동산의 처분금지를 명하는 경우 등에서 집행비용의 추심은 별도로 집행비용액 확정결정을 받아 이에 기초하여 따로 금전집행을 하여야 한다.

나. 담보권 실행 등을 위한 경매에서 비용의 추심

담보권 실행 등을 위한 경매의 비용은 매매물건의 매각대금으로부터 먼저 공제하여 추심한다.

경매비용은 집행기관이 집행기록과 채권자가 제출한 채권계산서를 근거로 하여 직권으로 계산하여 추심한다.

- 145 이미 경매개시결정이 있는 부동산에 대하여 다시 담보권 실행 등을 위한 경매를 신청한 경우에 선행의 경매신청이 취하되거나 취소되지 않는 한 그 신청비용을 우선적으로 배당받을 수 없음은 강제경매의 경우와 같다.

2. 집행비용액 확정결정

민사집행법 53조 1항의 규정에 따라 채무자가 부담하여야 할 집행비용으로서 그 집행 절차에서 변상받지 못한 비용은 채권자의 신청을 받아 집행법원이 결정으로 정한다(민집규 24조 1항). 또 민사집행법 53조 2항의 규정에 따라 채권자가 변상하여야 할 금액도 채무자의 신청을 받아 집행법원이 결정으로 정한다(민집규 24조 1항). 집행비용액 확정결정 절차에서의 법원의 사무는 사법보좌관규칙 2조 1항 1호에 의하여 사법보좌관이 행한다.

가. 신청

비용액 확정결정의 신청에는 민사소송법 110조 2항의 규정이 준용된다(민집규 24조 2항). 따라서 비용계산서, 그 등본과 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 제출하여야 한다.

나. 절차

신청을 받은 집행법원은 결정하기 전에 상대방에게 비용계산서의 등본을 교부하고 이에 대한 진술을 할 것과 일정한 기간 이내에 비용계산서와 비용액을 소명하는 데 필요한 서면을 제출할 것을 최고하여야 한다(민집규 24조 2항, 민소 111조 1항).

신청을 받은 집행법원은 법원사무관등에게 소송비용액을 계산하게 하여야 한다(민집규 24조 2항, 민소 115조).

다. 재판

비용액을 확정하는 재판은 결정으로 한다(민집규 24조 1항). 신청액이 일부만 인용된 146
경우에도 일부 기각의 재판은 하지 않는다. 확정계산서는 별지로 결정문에 첨부하는데, 당사자(신청인)가 제출한 비용계산서의 사본을 수정하여 사용할 수도 있다.

라. 불복신청방법

비용액 확정결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. 다만 집행비용액 확정결정은 집행 종료 후의 재판으로서 민사집행법 15조 1항의 '집행절차에 관한 집행법원의 재판'에 해당하지 아니하고 그 결정에 대하여는 민사집행규칙 24조 2항에 의하여 준용되는 민사소송법 110조 3항에 따라 민사소송법상의 즉시항고가 허용될 뿐이므로, 집행비용액 확정결정에

대한 즉시항고에는 항고이유서 제출에 관한 민사집행법 15조 3항, 5항이 적용될 수 없다 (대결 2011. 10. 13. 2010마1586).

마. 집행

집행비용액 확정결정은 집행권원이 된다(민집 56조 1호). 따라서 채권자는 이에 기초하여 강제집행을 할 수 있다.

한편 집행비용액 확정결정에 따른 집행비용액 상환의무도 소송비용액상환의무의 경우(대판 2008. 7. 10. 2008다10051)와 마찬가지로 집행비용액 확정결정이 확정됨으로써 비로소 이행기가 도래하고, 채무자가 그 이행기가 도래하였음을 안 때로부터 지체책임을 진다고 할 것이다.

3. 집행비용의 계산

가. 총설

147 (1) 집행기관이 강제집행 또는 담보권 실행 등을 위한 경매를 실시하여 본안에 관한 청구 채권액을 교부(배당)하는 것과 동시에 채무자 또는 경매물건소유자로부터 집행비용을 추심하여 이를 채권자에게 지급하기 위해서는 집행비용의 구체적인 액을 산정할 필요가 있다. 집행비용은 채권자의 청구가 없어도 집행기관이 직권으로 계산한다. 그러나 전부를 직권으로 탐지하여 계산할 의무는 없다.

따라서 집행기관은 집행기록에 명백히 나타난 것은 집행기록에 의하여 계산하고 집행기록상 명백하지 아니한 비용은 채권자가 제출한 채권계산서와 소명자료에 의하여 계산하여야 한다.

채권자는 민사집행법 84조 4항의 채권신고 또는 민사집행법 253조의 계산서에 집행비용을 기재하여 제출할 수 있으나 집행기관은 그 기재를 그대로 인용하여서는 아니 되고 이를 집행기록이나 그 밖의 소명자료와 대조하여 조사하여야 한다.

채권자가 채권계산서를 제출한 경우에 이에 기재된 집행비용의 항목, 총액에 구속될 필요는 없고 집행기록상 명백한 비용에 관하여는 채권자가 특히 청구하지 않는다는 취지의 의사표시를 하지 않는 한 비용항목을 추가하거나 금액을 증액할 수 있다.

(2) 집행비용의 계산은 채권자가 집행을 실시 또는 그 준비를 위하여 비용이 소요되는 각 행위를 한 시점을 기준으로 하여 그 당시에 시행되고 있던 집행비용계산의 근거명령에

따라서 하여야 한다.

나. 각종의 집행에서 집행비용의 계산방법

(1) 부동산 강제경매

(가) 부동산 강제경매절차에서 배당을 실시하는 경우이거나 이를 실시하지 아니하는 경우이거나를 불문하고 집행비용의 계산관계를 명확히 할 필요가 있으므로 실무상으로 집행비용계산서[전산양식 A3122]를 작성하여 집행비용의 내역을 밝히고 있다. 이 집행비용계산서는 법률상 요구되는 것은 아니므로 이것이 없더라도 배당표의 효력에 영향을 주지는 아니하나, 추심되지 아니한 비용에 대하여는 후일 집행비용액 확정결정신청을 할 수 있으므로 배당표에 기재되어 추심되는 비용의 내역을 명백히 밝힘이 타당할 뿐만 아니라 집행비용계산서를 이용하는 것이 집행비용의 계산상으로도 편리하다.

148

집행비용계산서는 법원사무관등이 작성하여 법원의 승인을 받는다. 그러나 승인절차가 따로 정해져 있는 것은 아니고 실무상으로는 배당표상의 집행비용항목에 이를 인용함으로써 승인에 갈음한다.

(나) 집행비용의 종류에 따른 계산방법은 다음과 같다.

인지대는 경매신청서 등에 첨부된 인지액에 의하여 산출한다. 다만 과첩된 인지액은 집행비용으로 되지 아니하므로 이를 계상하여서는 안 된다. 집행문부여신청서, 집행권원 송달증명신청서 등의 첨부 인지대는 집행기록에 편철되어 있는 집행문 또는 증명서의 존재에 의하여 이를 산출하여도 무방하다.

서기료는 원칙적으로 민사소송비용규칙 2조 1항에 정하여진 바에 따라서 1면 16행 이상, 1행 20자 이상으로 된 1면마다 250원으로 하고, 1면에 미달한 경우에는 1면으로 본다. 그러나 법무사에게 지급한 또는 지급할 서기료는 대한법무사협회의 회칙이 정하는 법무사의 보수에 관한 규정에 정한 금액으로 하되(민비규 2조 3항), 그 전부를 소송비용에 산입하는 것이 소송목적의 값, 사건의 특성과 난이도 등에 비추어 현저히 부당하다고 인정되는 경우에는 법원은 상당한 정도까지 감액 산정할 수 있다(민비규 2조 4항). 법무사가 작성한 서류인 것이 분명하지 아니한 경우에는 당사자가 작성한 것으로 본다. 집행문부여신청서 등 집행기록에 나타나지 아니한 서류의 서기료는 채권자의 소명이 있어야 한다.

경매개시결정등기의 등록면허세는 등기촉탁서의 사본에 기재되어 있는 액에 의하여 계상한다.

송달료는 송달료입출명세서에 의하여 산출한다. 채권자 또는 그 대리인 등에 대한 사무

연락비용, 송달료 등의 추가납부통지비용 등은 집행비용으로 계상할 수 없다. 송달료 중 집행권원이나 승계집행문의 송달료 등 기록상 확인할 수 없는 것은 채권자가 소명자료를 제출한 경우에만 계산한다.

등기신청수수료는 등기사항증명서에 부기된 수수료 금액에 의하여 계산한다.

현황조사비용, 감정평가비용, 공고비용, 매각수수료 등은 예납금에서 지출되므로 법원 보관금 수불명세서의 기재에 의하여 산출한다.

149

[전산양식 A3122] 집행비용계산서

○ ○ 지 방 법 원		
집행비용계산서		
사 건 20 타경 부동산강제(임의)경매		
순 번	내 역	금 액
1	경매신청서 등 첨부 인지대	원
2	경매신청서 서기로	원
3	등본수수료	원
4	경매개시결정등기등록면허세(지방교육세 포함)	원
5	등기신청수수료	원
6	송달료	원
7	현황조사비용	원
8	감정평가비용	원
9	공고비용	원
10	매각수수료	원
11	기타	원
합계		원
집행기록에 의하여 위 계산을 하였습니다.		
2000. ○. ○.		
법원사무관		㉠

(2) 부동산 강제관리

150

관리인은 부동산의 수익금 중에서 집행비용을 공제하여 채권자에게 지급한다. 집행비용 중 관리비용은 관리인이 계산하여 수익금 중에서 공제하게 되므로, 집행법원은 강제관리 신청비용, 강제관리개시결정등기를 위한 등록면허세 등 협의의 집행비용만을 계산하여 배당 전에 관리인에게 이를 통지하면 된다. 그 계산방법은 부동산 강제경매에 준한다.

(3) 선박 등에 대한 강제집행

선박, 자동차·건설기계·소형선박, 항공기에 대한 집행은 원칙적으로 부동산 강제경매에 관한 규정을 준용하므로 집행비용의 계산도 부동산 강제경매의 경우에 준하여 행한다. 다만 등기사항증명서 송부의 신청(민집 177조 2항), 감수보존처분의 신청(민집 178조 1항) 등 부동산 강제경매와 다른 집행비용이 있는데, 전자에 관하여는 신청서와 송달료입출명세서 등에 의하여 신청서 서기로, 첩부 인지액, 송부촉탁비용 등을 산출하고, 후자에 관하여는 신청서 및 법원보관금 수불명세서에 의하여 신청서 서기로, 인지액, 감수보존처분의 필요비용으로서 집행관에게 지급된 비용을 계산한다.

(4) 유체동산에 대한 강제집행

(가) 집행실시비용은 자격증명서교부신청비용을 제외하고는 기록상 명백히 나타나 있으므로 기록에 의하여 집행관이 계산한다. 특히 집행관수수료와 그 직무집행에 필요한 비용은 채권자의 예납금에서 지급되므로 사건별 예납금 등 출납내역서의 기재에 의하여 계산하면 된다. 다만 여기에 기재된 것이라도 채무자가 부담할 것이 아닌 비용(예를 들어, 채권자의 사정으로 집행이 연기된 경우에 집행관이 받을 수수료와 여비 등)은 제외되어야 한다.

(나) 집행준비비용 중 집행기록에 나타난 비용, 예를 들어 집행문부여신청서, 집행권원 송달증명신청서의 첩부 인지대(이러한 비용은 집행문 또는 송달증명서의 존재에 의하여 추정된다) 등은 채권자가 특별히 청구하지 않는다는 의사표시를 하지 않은 한 집행기록에 의하여 계산하여야 한다.

151

집행기록에 나타나지 아니한 비용, 예를 들어 집행문부여신청서, 집행권원 송달증명신청서의 서기로 등은 채권자가 소명자료를 제출한 경우에만 계산한다.

(다) 집행관은 매각기일조서에 집행비용의 총액 및 그 내역을 기재하여야 한다(예를 들어, 집행비용 총 〇〇〇원, 내역 매각수수료 〇〇원, 노무비 〇〇원, 일당 〇〇원, 감정수수료 〇〇원과 같다). 집행비용의 계산에 대하여 불복신청을 할 수 있으므로 그 계산의 근거를 명확히 하여 놓을 필요가 있기 때문이다.

(5) 동산의 배당절차

유체동산, 채권과 그 밖의 재산권에 대한 집행에서 배당절차가 실시되는 경우에 집행법원은 압류채권자가 제출한 채권계산서와 소명자료, 집행관으로부터 송부받은 집행기록, 집행법원의 집행기록 및 배당절차 기록 등에 의하여 집행비용을 계산한다. 채권자가 채권계산서를 제출하지 아니한 경우에는 기록에 의하여 계산한다.

법원사무관등은 집행비용의 계산관계를 명확히 하기 위하여 배당표를 작성하면서 집행비용계산서를 작성하여야 한다. 이 집행비용계산서는 부동산 강제경매의 배당절차에서 작성되는 집행비용계산서에 준하여 작성한다.

(6) 채권과 그 밖의 재산권에 대한 강제집행

(가) 채권에 대한 집행에서 추심명령, 전부명령에 의하여 현금화하는 경우에 집행법원은 채권압류 및 추심 또는 전부명령을 발할 시에 채권자가 청구하는 집행비용에 대하여는 이를 인정할 필요가 있고 그 액도 계산하여야 한다. 그 계산은 신청서의 기재와 그 외의 다른 자료를 근거로 한다.

152 압류한 채권을 특별한 현금화방법(매각, 임의매각, 평가액에 의한 양도 등)에 의하여 현금화하는 경우에는 채권압류명령에 표시된 집행비용 외에 현금화 비용, 예를 들어 특별현금화명령 신청비용, 임의매각수수료 및 비용, 평가인에 대한 평가료 등을 부가하여 계산하여야 한다. 다만 집행관에 의한 매각의 경우에 현 실무에서는 채권자가 집행관에게 매각을 위임하면서 집행관의 매각수수료와 비용을 직접 예납하고 집행관이 매각대금으로부터 그 비용을 추심하여 채권자에게 지급하고 있으므로 집행법원은 이를 계산할 필요가 없다.

(나) 그 밖의 재산권에 대한 집행에서 양도명령을 발하는 경우에는 압류명령에 기재되어 있는 비용(압류명령신청서에 의하여 청구된 비용에 한하여 압류명령에 계상됨은 전술한 바와 같다) 외에 양도명령을 위하여 소요된 비용, 예를 들어 양도명령신청비용, 평가료, 양도명령송달비용 등을 부가하여 계산해서 양도명령에 표시하여야 한다. 이 경우에도 담임 법원사무관등은 집행비용계산서를 작성하여야 한다.

그 밖의 재산권을 매각명령 등으로 현금화하여 그 대금을 채권자에게 지급하거나 채권자들에게 배당하는 경우에는 집행법원이 현실의 현금화에 관여하므로 압류명령에 집행비용이 기재되어 있지 아니하더라도 집행법원은 직권으로 압류명령 및 현금화에 필요한 제반 비용을 계산하여야 한다. 다만 집행관에 의한 매각으로 현금화하는 경우에는 채권에 대한 특별현금화의 경우와 마찬가지로 채권자가 집행관에게 매각을 위임할 때 매각수수료

와 비용을 예납하고 집행관은 그 매각대금에서 이를 추심하여 채권자에게 지급하는 것이 실무이므로 이러한 경우에 집행법원은 이를 계산할 필요가 없다.

(7) 담보권 실행 등을 위한 경매

담보권 실행 등을 위한 경매의 절차비용 계산은 부동산 강제경매 등 위에서 본 금전채권에 기초한 각 강제집행(단, 부동산 강제관리는 제외한다)에 관하여 설명한 바에 준하여 행한다.

4. 집행비용의 계산에 대한 불복신청

가. 집행관이 계산한 경우

유체동산에 대한 집행에서 집행관이 계산한 집행비용액에 대하여 불복이 있으면 채권자 또는 채무자는 법원에 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다(민집 16조). 이의신청을 할 수 있는 시기는 그 성질상 집행종료 후라도 무방하다고 할 것이다. 153

이의신청은 서면에 의하며(민집규 15조 1항) 신청서에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 한다(인지 9조 5항 4호, 재민 91-1).

이의가 이유 있다고 인정될 때에는 신청의 취지에 따라 집행비용계산의 변경 또는 반환을 명한다.

나. 집행법원이 계산한 경우

배당기일에 출석한 각 채권자와 채무자는 배당표에 기재된 집행비용의 계산에 대하여 불복이 있으면 이의할 수 있다(민집 151조, 256조, 268조 등).

법원은 위 이의가 이유 있으면 집행비용을 다시 계산하여 배당표의 기재를 경정한다. 집행비용의 재계산을 즉시 할 수 없는 경우에는 배당의 실시를 연기하고 다시 배당기일을 정하여 경정한 배당표에 따라서 배당을 실시한다.

법원이 위 이의가 이유 없다고 판단하여 배당표를 경정하지 아니하는 경우 이의진술인의 불복방법에 관하여는 견해가 대립하고 있다. 배당이의의 소를 제기할 수 없다고 보는 견해는, 법원은 그대로 배당을 실시하고 이의진술인은 집행에 관한 이의신청(민집 16조)을 할 수 있다고 한다. 이에 대하여 배당이의의 소를 제기할 수 있다고 보는 견해는, 법원은 이의가 완결되기 전에는 이의가 없는 부분에 한하여 배당을 실시하여야 한다고 한다.

제7절 집행비용의 변상

154 (1) 채권자가 강제집행을 완료한 후 그 강제집행의 기초가 된 집행권원이 파기된 때에 채권자는 채무자로부터 추심한 집행비용을 채무자에게 변상하여야 한다(민집 53조 2항, 57조).

집행권원이 파기된 때란 집행권원이 소급적으로 실효되는 경우를 의미하는 것으로, 가집행의 선고가 있는 판결이 상급심에서 취소 또는 파기되거나 확정판결 또는 이에 준하는 화해조서, 인낙조서 등이 재심 또는 준재심의 소에 의하여 취소되는 경우 등이 있다.

그러나 청구이의의 소에 의하여 집행이 배제되는 때는 기초가 된 판결이 소급하여 실효된 경우가 아니므로 채무자가 당연히 비용의 변상을 구할 수는 없다.

(2) 채무자가 집행비용의 변상을 구하는 방법으로 가집행의 선고가 있는 판결에 기한 집행의 경우에는 민사소송법 215조 2항에 규정된 손해배상의 신청에 의할 수 있고, 그 밖의 경우에도 이에 준하여 기초가 된 집행권원의 취소를 구하는 소송절차에서 집행비용의 변상을 구하는 신청을 할 수 있다(다수설).

한편 집행권원을 취소하는 재판이 확정된 후에 그 재판에 기하여 집행법원에 집행비용의 변상을 구하는 집행비용액 확정결정을 신청할 수도 있다(민집규 24조 1항).

(3) 채무자가 변상을 구할 수 있는 비용의 범위에 관하여는 ① 채권자가 본안의 청구와 동시에 또는 별개 독립의 집행권원에 의하여 추심한 집행비용에 한하고 채무자가 지출한 비용, 예를 들어 집행정지신청에 관한 비용이라든가 집행연기신청비용 등은 이에 포함되지 않는다고 하는 견해와 ② 채권자가 이미 채무자로부터 추심한 집행비용뿐만 아니라 채무자가 지출한 비용도 이에 포함된다고 하는 견해로 나뉘어 있다. 후설이 다수설이나, 이에 의하더라도 채무자의 부적법한 신청 또는 이유 없는 신청으로 인하여 생긴 비용은 포함되지 않는다.

제7장 집행에 관한 담보·보증·공탁

제1절 의의

(1) 집행법상의 담보는 당사자 또는 제3자가 집행을 실시하거나 또는 집행을 정지·취소함으로써 인하여 상대방에게 주는 손해를 담보하기 위하여 제공되는 것이다.

(가) 채무자가 제공하는 담보로는, ① 재심 또는 상소추후보완의 신청에 의한 집행정지·취소(민소 500조 1항), ② 가집행의 선고가 붙은 판결에 대한 상소 또는 정기금의 지급을 명한 확정판결에 대한 변경의 소제기로 인한 집행정지·취소(민소 501조, 500조 1항), ③ 즉시항고에 의한 집행정지(민집 15조 6항 단서), ④ 집행에 관한 이의신청에 의한 집행정지(민집 16조 2항), ⑤ 집행문부여 등에 관한 이의신청에 의한 집행정지(민집 34조 2항, 16조 2항), ⑥ 청구에 관한 이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소에 의한 집행정지·취소(민집 46조 2항), ⑦ 압류금지물의 확장 또는 압류금지물에 대한 압류명령 취소·변경에 의한 집행정지(민집 196조 3항, 16조 2항), ⑧ 가압류·가처분에 대한 이의신청에 의한 변경 또는 취소 결정(민집 286조 5항, 301조), ⑨ 담보제공을 이유로 한 가압류·가처분의 취소신청에 의한 취소(민집 288조 1항, 301조, 307조 1항), ⑩ 소송물인 권리 또는 법률관계가 이행되는 것과 같은 내용의 가처분을 명한 재판에 대하여 이의신청 또는 상소가 있는 경우에 하는 가처분의 집행정지 또는 집행처분의 취소(민집 309조 1항)를 할 때의 담보 등이 있다.

(나) 채권자가 제공하는 담보로는, ① 재심 또는 상소추후보완의 신청에 대하여 재심피고 또는 추후보완신청의 상대방의 집행실시(민소 500조 1항), ② 가집행의 선고가 있는 판결에 대한 상소의 제기에 있어서 승소자의 집행실시 또는 정기금의 지급을 명한 확정판결에 대한 변경의 소제기에 있어서 상대방의 집행실시(민소 501조, 500조 1항), ③ 즉시항고에 있어서 상대방이 하는 집행의 속행(민집 15조 6항 단서), ④ 집행에 관한 이의신청 시 채권자가 하는 집행의 속행(민집 16조 2항), ⑤ 집행문부여등에 관한 이의신청에 있어서 상대방

이 하는 집행의 속행(민집 34조 2항, 16조 2항), ⑥ 청구에 관한 이의의 소, 집행문부여에 대한 이의의 소에서 집행정지에 대하여 피고가 하는 집행의 속행(민집 46조 2항), ⑦ 제3자 이의의 소의 피고가 하는 집행의 속행(민집 48조 3항), ⑧ 채권자의 신청에 의한 침해방지를 위한 보전처분(민집규 44조 1항, 2항), ⑨ 채권자의 신청에 의한 부동산 관리명령으로서의 인도명령(민집 136조 3항), ⑩ 압류금지물의 범위변경에 있어서 집행의 속행(민집 196조 3항, 16조 2항), ⑪ 압류금지채권의 범위변경에 있어서 집행의 속행(민집 246조 3항, 196조 3항, 16조 2항), ⑫ 가압류·가처분(민집 280조 2항, 3항, 301조), ⑬ 가압류·가처분에 대한 이의신청에 있어서 인가 또는 변경(민집 286조 3항, 301조), ⑭ 가압류·가처분 취소결정에 대한 즉시항고의 경우 취소결정의 효력정지(민집 289조 1항, 301조)를 할 때의 담보 등이 있다.

(다) 제3자가 제공하는 담보로는, ① 제3자이의의 소에 의한 집행의 정지·취소(민집 48조 3항, 46조 2항), ② 제3자가 제기한 즉시항고에 의한 집행정지(민집 15조 6항 단서), ③ 제3자가 제기한 집행에 관한 이의신청에 의한 집행정지(민집 16조 2항), ④ 최고가매수 신고인의 신청에 의한 침해방지를 위한 보전처분(민집규 44조 1항, 2항) ⑤ 매수인의 신청에 의한 부동산 관리명령으로서의 인도명령(민집 136조 3항)을 할 때의 담보 등이 있다.

(라) 집행에 관한 담보도 소송비용의 담보 등과 함께 소송상의 담보에 속하므로 민사집행법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소송비용의 담보에 관한 민사소송법 122조, 123조, 125조 및 126조의 규정이 준용된다(민집 19조 3항).

- 157 (2) 이에 대하여 집행법상 일정한 보증의 제공을 요구하고 있는 경우가 적지 않다. 예를 들어, 부동산에 대한 강제경매에서 최저매각가격으로 남을 가망이 없다고 인정될 때 경매절차의 속행을 위하여 압류채권자에게 보증을 제공하도록 한 것(민집 102조 2항, 104조 1항)이라든가 매수신청 시 매수신청인에게 보증을 제공하도록 한 것(민집 113조)을 비롯하여 매각허가결정에 대한 항고를 할 때 항고인이 제공하는 보증(민집 130조 3항), 선박에 대한 강제경매에 있어서 강제경매절차를 취소받기 위하여 채무자가 제공하는 보증(민집 181조 1항) 등이 이에 속한다.

집행법상 담보는 상대방이 입게 될 손해배상의 이행을 확보하기 위하여 제공되는 것임에 반하여, 여기서 말하는 보증은 모두 배당재단의 형성을 확보하기 위하여 제공된 것으로 그 성질이 전혀 다르다. 따라서 보증에 관하여는 집행법상의 담보에 관한 규정이 적용될 여지가 없고 각 규정에서 개별적으로 정하는 바에 따라 처리된다.

- (3) 집행법상의 공탁은 채무자, 제3채무자 또는 집행관이 상대방에 대한 손해담보를 위

해서가 아니라 이행의 강제를 면하기 위하여 혹은 손해를 피하기 위하여 혹은 절차의 완결을 위하여 집행의 목적물이나 이에 갈음하는 금전을 공탁소에 공탁하는 것을 말한다. 이 공탁물은 종국적으로 집행채권자 등에 대한 배당재단이 되는 것으로서 공탁소가 이를 관리하되, 집행법원의 지급위탁에 따라 공탁소가 각 채권자 등에게 지급하게 된다. 강학상 ‘집행공탁’이라 한다.

집행법상의 공탁(집행공탁)은 손해의 담보라는 성질이 없다는 점에서 집행법상의 담보와는 그 개념과 본질이 판이함에도 불구하고, 담보제공의 방법으로 거의 모두 공탁제도를 이용하고 있기 때문에 양자를 혼동하는 경우가 많다. 그러나 집행공탁과 담보제공 방법으로서의 “재판상 담보공탁”은 구별되어야 한다.

집행공탁에 해당하는 것으로서는 채권추심의 신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있는 때에 채권자가 추심한 금전을 공탁하는 경우(민집 236조 2항), 보전집행의 정지·취소를 위하여 채무자가 목적물에 갈음하는 금전을 공탁하는 경우(민집 282조, 299조), 압류채권의 제3채무자가 채무를 면하기 위하여 채무액을 공탁하는 경우(민집 248조 1항, 2항, 3항), 배당협회가 불성립된 때 또는 여러 채권자를 위하여 동시에 금전을 압류한 경우에 집행관이 매각대금을 공탁하는 경우(민집 222조 1항, 2항), 집행관이 가압류한 금전을 공탁하거나 가압류목적물을 매각하여 매각대금을 공탁하는 경우(민집 296조 4항, 5항) 등이 있다. 158

제2절 집행에 관한 담보제공의 방법

1. 원칙

담보의 제공은 금전 또는 법원이 인정하는 유가증권을 공탁하거나, 대법원규칙이 정하는 바에 따라 지급을 보증하겠다는 위탁계약을 맺은 문서를 제출하는 방법으로 한다(민집 19조 3항, 민소 122조). 여기서 담보를 제공한다는 말은 현실적으로 금전 또는 유가증권을 법원에 제공하는 것을 뜻하는 것이 아니라 담보제공자가 실제로 공탁법의 절차에 따라 공탁관에게 공탁을 하고 이로부터 공탁을 수리한다는 취지의 기재가 있는 공탁서(은행의 납입증명이 있는 것)를 받아 이를 법원에 제출하거나 대법원규칙이 정하는 바에 따라 지급보증위탁계약을 맺은 문서(이하 ‘보증서’) 원본을 법원에 제출하는 것을 가리키며 이로써 비로소 담보를 제공한 것으로 된다.

민사집행법 19조 1항은 “이 법의 규정에 의한 담보제공이나 공탁은 채권자나 채무자의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원 또는 집행법원에 할 수 있다”고 규정하고 있다. 이 규정은 공탁소의 토지관할을 정한 것이 아니라 공탁을 한 후 그 공탁서를 제출할 법원을 정한 것으로 해석하는 것이 통설적 견해이고, 담보제공자는 임의로 정한 공탁소에 공탁을 할 수 있지만, 담보제공명령을 발한 법원 소재지 공탁소에 공탁하는 것이 바람직하다(행정예규 952호 참조).

- 159 공탁서의 제출이 있을 때에는 그 사본을 받아 원본과 대조한 후 담임 법원사무관등이 사본의 여백에 원본과 대조하여 틀림이 없다는 뜻을 기재하고 서명 또는 날인한 다음 담당 판사(사법보좌관)의 확인을 받은 후 기록에 편철하고 원본은 제출자에게 반환한다(재판사무규 13조).

그리고 보증서 원본의 제출이 있으면 담임 법원사무관등은 보증서 원본에 접수인을 날인하여 이를 사건기록에 편철한 다음 담당 판사(사법보좌관)에게 회부한다(재민 2003-5).

한편 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률과 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙이 2013. 9. 16.부터 보전처분 등 신청사건에 적용됨에 따라, 보전처분 신청사건이나 그 부수사건에서 금전 또는 유가증권을 담보로 제공한 사람은 재판사무시스템으로 전송된 공탁관리시스템의 공탁정보로써 공탁서 원본 제출에 갈음할 수 있고, 보전처분 신청사건에서 채권자가 법원의 허가결정에 따라 보증서를 제출하는 방법으로 담보를 제공하는 경우 채권자는 은행 등의 전산시스템을 통해 법원의 전산시스템에 적법한 보증보험계약 체결사실을 확인할 수 있는 정보를 전송하는 방법으로 보증서 원본 제출에 갈음할 수 있게 되었다(재일 2012-1 110조 참조).

2. 예외

담보의 제공은 금전 또는 유가증권을 공탁하거나 보증서를 제출하는 방법에 의함이 원칙이나 당사자들 사이에 특별한 약정이 있으면 그 약정에 의한다(민집 19조 3항, 민소 122조).

따라서 당사자가 약정에 의하여 보증인으로 하여금 보증케 하거나 저당권, 질권 등 담보물권을 설정하기로 한 때에는 이에 따른다. 이 경우에는 담보계약서와 그 계약의 이행을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 담보제공의 결정 전에 당사자 사이에 계약이 성립한 경우에 당사자의 신청이 있으면 법원은 그 계약에 대응하는 결정을 하여야 한다.

3. 담보제공의 방법

160

가. 담보제공명령

(1) 현금 공탁에 의한 담보제공의 경우

담보를 제공할 의무는 법원의 담보제공을 명하는 재판에 의하여 구체화되므로 이러한 담보 제공명령이 있어야만 공탁을 할 수 있다(대결 2010. 8. 24. 2010마459).

담보제공명령은 법원이 직권으로 하며 담보액과 담보제공의 기간을 정하여야 한다. 다만 가집행을 위한 담보나 가집행을 면제받기 위한 담보의 경우에는 판결 주문에 담보액이 표시되며 담보의 제공이 정지조건으로 되므로 담보제공의 기간을 정할 필요가 없다.

담보제공명령은 집행정지결정, 가압류·가처분결정 등 재판이 있기 전에 미리 독립한 결정으로 하는 방법과 가집행의 선고가 있는 판결이나 집행정지결정, 가압류·가처분결정 등의 재판에 포함시켜 하는 방법이 있다.

실무상 보통 전자의 방법이 잘 쓰이나, 가압류·가처분결정에 대한 이의신청의 결과 담보액을 증액하는 경우 등에 있어서는 후자의 방법이 사용되며, 이때에는 담보제공의 기간을 정할 필요가 없다. 또한 상소제기의 경우 원심법원과 상소심법원의 거리가 먼 때에 상소인으로 하여금 집행정지의 목적을 달성하게 하기 위하여도 이 방법이 이용된다.

전자의 경우에는 “○○○에게 ○○○을 위하여 담보로 이 명령을 고지받은 날부터 ○일 이내에 ○○원을 공탁할 것을 명한다.”라고 하고, 후자의 경우에는 “○○○에게 ○○○을 위하여 담보로 ○○원을 공탁할 것을 조건으로(또는 ……공탁한 때에는)….”라고 하는 것이 통례이다.

당사자가 여럿인 경우에는 피담보채권이 가분인가 불가분인가를 고려하여 각별로 또는 공동으로 담보를 제공할 것을 명한다. 예를 들어, “신청인 甲은 ○○원, 같은 乙은 ○○원……”, “피신청인 甲을 위하여 ○○○원, 같은 乙을 위하여 ○○○원……”, “신청인들은 공동으로 ○○○원……” 등과 같다. 각별 또는 공동의 표시가 없는 때에 담보권리자가 복수인 경우에는 준공유와 마찬가지로의 관계가 생기고 담보제공자가 복수인 경우에는 균등한 비율에 의하여 각별로 제공하도록 한 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 제3자가 공동공탁자 중 일방의 공탁금 회수청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 한 경우에 그 압류 및 추심명령은 공탁자 사이에 균등한 비율에 의한 공탁금액의 한도 내에서 효력이 있으므로, 담보공탁금을 전액 출연한 공탁자는 그 압류채권자에 대하여 자금 부담의 실질관계를 이유로 대항할 수 없다(대판 2015. 9. 10. 2014다29971).

161

(2) 유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우

담보로서 유가증권의 공탁을 인정하는 때에는 그 종류와 수량을 명시한다. 예를 들어, 장기신용채권 제○호 액면 ○○○원권 ○○장 등과 같다.

담보제공명령에 구체적으로 유가증권의 종류, 수량 등이 지정되어 있지 아니하면 담보제공자는 민사소송법 126조의 담보물변경 절차를 유추하여 공탁 전에 담보제공명령을 한 법원 등에 신고하여 그 종류, 수량의 지정을 받아 공탁하여야 한다(이에 대하여는, 당사자가 자기 스스로 판단하여 상당하다고 인정되는 유가증권을 공탁하면 되고 만약 법원이 판단하여 부족하다고 인정되면 새로이 기간을 정하여 추가로 공탁할 것을 명할 것이라는 견해도 있다).

실무상으로는 국채나 공채가 주로 지정되고 있으나 반드시 이에 한하는 것은 아니다. 그러나 담보는 성질상 종국에는 현금화할 수 있어야 하므로 현금화가 용이하지 않거나 시세의 변동이 심하여 안정성이 없는 주권 등의 공탁을 인정하는 것은 적당하지 않다. 가령 담보제공자가 발행하는 당좌수표는 당좌수표 지급인인 금융기관 명의의 지급보증서를 별도로 제출하였다고 하더라도 특별한 사정이 없는 한 공탁할 유가증권으로 보기 어렵다(대결 2000. 5. 31. 2000그22). 그 가액은 액면가가 아니라 시장가격을 기준으로 하여 공탁할 수량을 정한다.

(3) 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공의 경우

- 162 보증서의 제출에 의한 담보제공명령은 담보제공의무자가 가압류신청과 같은 사건 신청의 서면에, 또는 사건 신청 후 별개의 신청서로 법원에 보증서의 제출에 의한 담보제공의 허가신청을 한 때에 이를 할 수 있다(민소규 22조 1항, 재민 2003-5).

법원은 당사자로부터 보증서의 제출에 의한 담보제공의 허가신청이 있으면 원칙적으로 이를 허가할 것이나, ① 제공하여야 할 담보액이 담보권리자의 손해를 담보하는 것뿐만 아니라 소명에 갈음하는 점과 담보권리자의 장래 집행을 확실성·편의를 확보하는 점까지 고려하여 결정되는 경우, 예를 들어 가집행선고 있는 판결에 대하여 상소의 제기가 있는 때의 강제집행의 일시정지를 위한 담보 또는 청구이의의 소의 제기가 있는 때의 강제집행의 일시정지를 위한 담보의 제공을 명하는 경우에는, 보증서에 의하여 담보되는 범위는 담보권리자의 손해액에 한정되고 이를 초과하는 부분에 대해서까지 미치는 것은 아니므로 보증서의 제출에 의한 담보제공을 허가할 것이 아니고(다만 이미 압류의 효력이 발생하여 강제집행의 확실성 등이 확보됨에 따라 강제집행의 일시정지에 따른 손해액만을 담보할

필요가 있는 때에는 그러하지 아니하다), ② 담보제공의무자가 금융기관 또는 보험회사인 경우에, 자기를 지급보증위탁계약의 쌍방 당사자로 하는 보증서의 제출로써 담보를 제공하는 것은 담보제공의무자와 지급보증을 하는 사람이 동일인이어서 담보로서의 가치가 없으므로 허용되지 아니하며, ③ 소명에 같은 보증(민소 299조 2항), 매각허가결정에 대한 항고에 있어서의 보증(민집 130조 3항, 268조, 269조), 가압류해방금액(민집 282조) 등의 경우에는, 각각 일정액의 현금 또는 유가증권을 공탁하거나 집행관에게 보관할 것을 정하고 있는 등 보증제공의 방식이 다르므로 성질상 보증서의 제출에 의한 담보제공이 허용되지 아니함을 유의하여야 한다(재민 2003-5).

허가결정의 방법과 그 문례는 담보제공결정 후에 허가결정을 허가신청서에 하는 경우와 별개의 서면으로 하는 경우가 각각 다르고 또 허가결정을 담보제공결정과 동시에 할 경우가 다른데, 그 구체적인 기재례와 실무상 사용되는 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A3140] 보증서제출에 의한 담보제공 허가신청 및 결정

163

지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공의 허가신청	
채 권 자	
채 무 자	
위 당사자 사이의 귀원 20 카단 부동산가압류신청사건에 관하여 채권자는 금 〇〇〇원의 담보제공을 명령받았는바, 민사집행법 제19조 제3항, 민사소송법 제122조에 의하여 지급보증위탁계약을 맺은 문서를 제출하는 방법으로 담보를 제공할 것을 허가하여 주시기 바랍니다. 2000. 〇. 〇. 채권자 ㉠ 또는 서명 〇〇지방법원 귀중 ----- 위 신청을 허가함. 2000. 〇. 〇. 판 사 ㉠	

* 이 방법에 의한 경우에는 채권자로부터 신청서 2통을 제출받아 그 중 판사의 허가결정이 있는 1통은 원본으로서 기록에 첨부하고, 나머지 1통에는 법원사무관등이 등본인을 날인하여 채권자에게 교부하고, 채권자는 그 등본을 지참하여 은행 등과 지급보증위탁계약을 체결한다.

164

[전산양식 A3141] 보증서제출에 의한 담보제공 허가결정(별도 결정)

○○지방법원	
결 정	
사 건	20 카단 부동산가압류
채 권 자	○ ○ ○
채 무 자	○ ○ ○
위 사건에 관하여 채권자가 담보로, 보증금액(보험금액)을 금 〇〇〇원으로 하는 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출할 것을 허가한다. 2〇〇〇. 〇. 〇. 판 사 인	

165

[전산양식 A3142] 담보제공명령과 동시에 하는 허가결정

○○지방법원	
담보제공명령	
사 건	20 카단 부동산가압류
채 권 자	〇〇〇
채 무 자	1. △△△ 2. ▽▽▽
위 사건에 관하여 채권자에게 담보로 이 명령을 고지받은 날부터 〇일 이내에 채무자 △△△을 위하여 금 〇〇〇원, 채무자 ▽▽▽을 위하여 금 〇〇〇원을 각각 공탁할 것을 명한다. 채권자는 위 각 금액을 보증금액(보험금액)으로 하는 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 각각 제출할 수 있다. 2〇〇〇. 〇. 〇. 판 사 인	
1. 위에서 정한 기일 안에 공탁하거나 지급보증위탁계약을 체결한 경우 그 정보가 전자적으로 법원에 제출되므로 별도로 공탁서 등을 제출하지 않아도 됩니다. 2. 신청 인용에 따른 등기촉탁을 위해 담보제공과 함께 등기수수료와 등록면허세를 납부하시기 바랍니다.	

[전산양식 A3143] 보증서를 제출받고 하는 가압류결정

166

○ ○ 지 방 법 원	
결 정	
사 건	20 카단 부동산가압류
채 권 자	
채 무 자	
주 문	
채무자 소유의 별지 기재 부동산을 가압류한다.	
채무자는 다음 청구금액을 공탁하고 집행정지 또는 그 취소를 신청할 수 있다.	
청구채권의 내용	2002. 2. 1.자 대여금
청 구 금 액	금 35,000,000원
이 유	
이 사건 부동산 가압류신청은 이유 있으므로 담보로 공탁보증보험증권(○○보험주식회사 증권번호 제○○○-○○○-○○○○○○호)을 제출 받고 주문과 같이 결정한다.	
2○○○. ○. ○.	
판 사 (인)	
주 : 「청구채권의 내용」에는 채권의 발생일자 및 발생원인 등을 간결하게 기재한다. (예시) 2002.	
1. 1.자 대여금	
※ 1. 이 가압류 결정은 채권자가 제출한 소명자료를 기초로 판단한 것입니다.	
2. 채무자는 이 결정에 불복이 있을 경우 가압류의나 취소신청을 이 법원에 제기할 수 있습니다.	

민집 276①, 280, 281①, 282

부동산·자동차·건설기계·소형선박 또는 금전채권에 대한 가압류신청사건에서 채권자는 가압류신청을 하는 때에 법원의 담보제공명령이 없더라도 부동산·자동차·건설기계·소형선박에 대한 가압류신청사건은 청구채권액(원금만을 기준으로 하고 이자, 지연손해금 등은 포함하지 않는다)의 1/10(10,000원 미만은 버린다)을, 금전채권에 대한 가압류신청사건은 청구금액의 2/5(다만 법원이 지역 사정 등을 고려하여 별도의 기준을 정한 경우에는 그 금액)를 보증금액(보험금액)으로 하는 보증서 원본을 제출하는 방법으로 담보제공의 허가신청을 할 수 있다. 다만 급여채권, 영업자예금채권에 대한 가압류신청을 하는 때에는 그러하지 아니하고, 채권자·채무자 중 일방 또는 쌍방이 여럿인 경우에는 각 채권자가 각 채무자를 위하여 위 보증금액에 해당하는 보증서 원본을 개별적으로 제출하여야 한다. 이 경우 채권자는 가압류신청서에 허가신청의 의사표시를 기재하여야 하는데, 그 기재례는 다음과 같다.

제1편
제7장
제2절

167

담보제공은 공탁보증보험증권(○○보험주식회사 증권번호 제○○○-○○○-○○○호)을 제출하는 방법에 의할 수 있도록 허가하여 주시기 바랍니다.

담당 법원사무관등은 보증서 원본에 접수인을 날인하여 사건기록에 편철하고, 아래와 같은 내용의 양식을 가압류신청서 다음 장에 편철한 다음 담당 판사에게 회부한다.

168

[전산양식 A3144] 담보제공명령

○○지방법원 20○○카단○○○○ 채권가압류 채 권 자 홍 길 동(70○○○○-10000000) 서울 서초구 서초동 ○○○ 채 무 자 김 갑 동(720000-10000000) 서울 강남구 역삼동 ○○○	
(1)허가	채권자에게 담보로 금 원을 채무자를 위하여 공탁할 것을 명하고, 현금공탁에 갈음하여 채권자가 제출한 보증서에 의한 담보제공을 허가함 2000. 0. 0. 판사 ㉠
(2)추가	담보제공명령 채권자에게 담보로 금 원을 채무자를 위하여 공탁할 것을 명한다. 위 공탁금액 중 금 원에 대하여는 채권자가 제출한 보증서에 의한 담보제공을 허가하고, 나머지 금 원은 이 명령을 고지받은 날로부터 일 이내에 현금공탁하여야 한다. 다만, 채권자는 위 나머지 금액 중 금 원을 현금공탁에 갈음하여 보증서로 제출할 수 있다. 2000. 0. 0. 판사 ㉠
(3)불허가	담보제공명령 채권자에게 담보로 이 명령을 고지받은 날로부터 일 이내에 채무자를 위하여 원을 공탁할 것을 명한다. 2000. 0. 0. 판사 ㉠

주) 1. 이 양식은 채권자가 부동산·자동차·건설기계 또는 금전채권에 대한 가압류신청을 하면서 미리 보증서원본을 제출하는 경우에 사용된다. 다만, 급여채권·영업자예금채권에 대한 가압류신청을 하는 때에는 이 양식을 사용할 수 없다.

2. 보증금액은 다음과 같다.

- ① 부동산·자동차·건설기계에 대한 가압류 신청사건 : 청구금액(원금만을 기준으로 하고 이자·지연손해금 등은 포함하지 않는다. 이하 같다)의 10분의 1(10,000원 미만은 버린다. 이하 같다)
- ② 금전채권에 대한 가압류 신청사건 : 청구금액의 5분의 2.

담당 판사가 보증서 제출에 의한 담보제공을 허가하는 때에는 (1)의 허가란에 기명날인 169
하고, 금액 기재 부분에는 채권자가 제출한 보증서상의 보증금액을 기재한다(담보금액을
감액하여 허가하는 경우에는 새로 정한 보증금액을 기재).

담당 판사가 담보제공을 추가하는 때에는 (2)의 추가란에 기명날인하고, 첫 번째 금액
기재 부분에는 총 담보금액을, 두 번째 금액 기재 부분에는 채권자가 제출한 보증서상의
보증금액을, 세 번째 금액 기재 부분에는 총 담보금액에서 채권자가 제출한 보증금액을 뺀
추가담보금액을, 네 번째 금액 기재 부분에 추가담보금액 중 보증서에 의한 담보제출을 허
가한 금액을 각 기재하며, 세 번째 금액 기재 부분 다음에 추가담보제공기한을 기재한다.

담당 판사가 보증서 제출에 의한 담보제공을 불허가하는 때에는 (3)의 불허가란에 기명
날인하고, 담보금액과 담보제공기한을 기재한다.

담임 법원사무관 등은 법원이 보증서 제출에 의한 담보제공에 대하여 불허가결정을 하
고 현금공탁을 명한 경우, 가압류신청을 각하·기각한 경우, 담보금액을 감액한 경우, 채권
자가 가압류신청을 취하한 경우, 가압류집행이 아직 개시되지 않거나 집행불능 된 경우에
는 채권자가 보증료(보험료)의 전부 또는 일부를 환급받을 수 있도록 제출된 보증서 원본
에 아래와 같은 고무인을 날인하거나 보증서 원본 뒷면에 그와 같은 양식이 인쇄되어 있는
경우에는 그 뒷면을 이용하여, 해당 항목에 표시 및 기명날인을 한 다음 원본을 채권자에
게 교부하고 그 사본을 기록에 편철하되, 그 사본 하단에는 원본 환부연월일을 기재하고
환부영수인의 기명날인 또는 서명을 받아야 한다. 다만 담보금액을 감액한 경우에는 보증
서 등본을 채권자에게 교부한다(재민 2003-5).

[전산양식 A3145] 보증서의 반환

170

○○보험주식회사 ○○지점 귀하

다음과 같은 사유로 지급보증위탁계약 원인이 전부 또는 일부 소멸되어 귀사가 발행
한 보증서(공탁보증보험증권)가 담보로 전부 또는 일부 제공되지 아니하였으므로 채권
자가 보증료(보험료)를 환급받을 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

☐ 불허가 ☐ 각하·기각 ☐ 감액(금 원) ☐ 취하 ☐ 미집행 ☐ 집행불능

2000. 0. 0.

법원사무관 ○ ○ ○

주) 1. ☐ 중 해당항목에 ☒ 표시를 한다.

2. 감액항목 중 금액부분은 채권자가 제출한 공탁보증보험증권상의 담보금액과 법원이 정한 담보
금액과의 차액을 기재한다.

3. 날인란에는 법원사무관 등의 사인이 아닌 직인을 날인한다.

(4) 담보액의 결정

법원은 피담보채권인 손해배상청구권의 발생가능성과 그 예상액을 판단하여 담보액을 정한다.

가령 집행정지의 경우를 예로 들면, 집행정지로 인하여 상대방이 입게 되는 손해란 이론 상으로는 집행정지의 잠정처분이 없었더라면 당장 강제집행을 할 수 있었을 터인데 집행 정지로 말미암아 집행이 그만큼 지연됨으로써 입게 되는 손해를 의미한다 할 것이므로, 금전채권의 경우에는 통상 집행이 지연되는 기간에 해당하는 지연손해금 상당이 그 손해 액이 되고 건물이나 토지 인도의 경우에는 차임 상당액이 그 손해액이 될 것이나, 실제로는 그사이에 채무자의 자력에 변동이 생겨 전혀 채권의 만족을 얻을 수 없게 되는 경우도 생길 수 있고 또 그사이 목적부동산이 처분되는 일도 있을 수 있기 때문에 그렇게 간단하 지 않다.

따라서 실무에서는 집행정지의 경우에 통상 인용된 소송목적의 값 전액(단 일부에 대하여 가집행의 선고가 있는 경우에는 그에 해당하는 값)을 담보로 제공하도록 하고 있다.

171 (5) 담보를 제공하지 아니한 때의 조치

집행정지결정 등에 앞서 기간을 정하여 담보제공을 명한 경우에 담보제공의무자가 소정의 기간 내에 담보를 제공하지 아니한 때에는 그 자체로 집행정지결정 등의 신청을 각하한다. 소정의 기간을 경과하였더라도 아직 신청이 각하되지 아니한 동안에 담보를 제공하면 신청을 인용하는 것이 통상적인 실무의 취급례이다.

(6) 담보물의 변경

법원은 담보제공자의 신청에 따라 법원의 결정이나 당사자 간의 약정으로 담보물을 변경할 수 있다(민집 19조, 126조). 이러한 담보물변경은 신규담보물의 액면가액이 절대적으로 동일하거나 그 이상이어야만 하는 것은 아니며 신담보물을 어떠한 종류와 수량의 유가증권이나 채권으로 할 것인가는 법원의 재량(대결 1988. 8. 11. 88그25)이지만, 담보권리자의 이익을 침해하지 않도록 원래의 공탁물에 상당한 합리적인 범위 내에서 결정하여야 한다.

담보물변경신청을 기각한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다는 규정이 없고, 이러한 담보물변경신청 기각결정은 항고를 일반적으로 허용한 민사소송법 439조, 440조의 적용대상이 아니므로, 이에 대하여는 민사집행법 23조 1항에 의하여 준용되는 민사소송법 449조의 특별항고로써만 불복할 수 있다(대결 2014. 1. 3. 2013마2042).

나. 공탁기관

공탁서를 제출할 법원에 관하여는 민사집행법 19조 1항에 별도의 규정이 있으나, 공탁할 공탁소에 관하여는 특별한 제한규정이 없으므로 담보제공자가 임의로 정한 공탁소에 공탁하면 된다. 통상 담보제공명령법원 소재지의 공탁소에 공탁하고 있다(행정예규 952호 3. 참조). 공탁사무는 지방법원장 또는 지방법원 지원장이 지정하는 법원서기관 또는 법원 사무관, 시·군법원의 경우에는 지방법원장 또는 지방법원 지원장이 지정하는 법원주사 또는 법원주사보가 행하므로(공탁 2조 1항) 그 지정을 받은 법원서기관 등이 공탁소가 된다.

172

제1편
제7장
제2절

다. 공탁절차

공탁절차는 공탁법과 공탁규칙에 의한다. 즉 공탁을 하려는 사람은 공탁서 2통을 작성하여 공탁관에게 제출하여야 한다(공탁 4조, 공탁규 20조 1항). 공탁관이 공탁신청서류를 접수한 때는 상당한 사유가 없는 한 지체 없이 모든 사항을 조사하여 신속하게 처리하여야 하고, 공탁신청을 수리할 때에는 공탁서에 공탁을 수리한다는 뜻과 공탁번호, 공탁물 납입 기일, 납입기일까지 공탁물을 납입하지 않을 경우에는 수리결정의 효력이 상실된다는 뜻을 기재한 다음 1통을 공탁자에게 내주어 공탁물을 공탁물보관자에게 납입하게 하여야 한다(공탁규 25조, 26조 1항). 공탁자는 위 서류에 공탁물을 첨부하여 이를 지정된 공탁물 보관자에게 납입하고 공탁물보관자로부터 공탁서에 공탁물을 납입받았다는 뜻을 적어 돌려받는다(공탁규 27조).

등록국채를 담보로 공탁하는 경우에는 담보의 뜻을 등록함으로써 담보 제공에 갈음할 수 있다(국채법 9조 2항). 담보제공자는 국채사무처리기관(한국은행의 본점, 지점 및 대리점)에 비치된 국채등록부에 담보의 등록을 하고 등록필통지서(국채법 시행규칙 23조)를 교부받아 이를 공탁서에 갈음하여 직접 법원에 제출한다.

라. 제3자 공탁

민사소송법과 민사집행법에는 당사자에 한하여 담보제공을 할 수 있다는 규정이나 제3자가 이를 하는 것을 금하는 규정이 없으므로 담보제공의무자를 위하여 제3자가 그 소유의 금전 또는 유가증권을 자기 명의로 공탁할 수 있다.

그러므로 당사자 본인에게 공탁명령이 나간 경우에도 제3자는 당사자를 대신하여 공탁할 수 있다.

이 경우 법원의 허가나 담보권자의 동의는 필요 없으나 제3자가 당사자를 대신하여 공탁한다는 취지를 공탁서 비고란에 기재하여야 할 것이다(공탁선례 2-16 참조).

173

제3절 집행에 관한 공탁의 방법

집행에 관한 공탁의 방법도 담보제공의 경우와 마찬가지로이다. 즉 공탁서를 받아 이를 민사집행법 19조 1항 소정의 법원에 제출하면 된다.

유체동산에 대한 금전집행에서 배당협약이 성립되지 아니하여 집행관이 매각대금을 공탁한 경우(민집 222조 1항), 추심신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있어 추심채권자가 추심한 금액을 공탁한 경우(민집 236조 2항) 또는 압류채권의 제3채무자가 채무액을 공탁한 경우(민집 248조 1항, 2항, 3항)에는 집행관, 추심채권자 또는 제3채무자는 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집 222조 3항, 236조 2항, 248조 4항).

신고의 방법은 공탁의 사유(압류명령이나 배당요구 등의 사건번호, 당사자, 집행법원), 공탁금액 및 공탁을 한 공탁소 등 공탁의 사정을 기재한 서면(사유신고서)에 공탁서와 집행절차에 관한 서류(민집 222조 3항의 경우)를 첨부하여 집행법원에 제출하여야 한다.

제4절 담보제공 또는 공탁증명서

담보를 제공하거나 공탁을 한 때에는 법원은 당사자의 신청에 따라서 증명서를 주어야 한다(민집 23조 1항, 민소 502조 2항).

당사자가 공탁서를 제출한 법원에 담보제공(공탁)증명 신청서를 제출하면 그 법원의 법원사무관등이 위 증명서를 작성하여 내주어야 한다.

담보제공을 조건으로 가집행의 선고가 있거나 집행정지결정을 받았을 때에 당사자는 위 담보제공증명서를 집행기관에 제출함으로써 집행개시 또는 집행정지를 할 수 있다.

[전산양식 A3146] 담보제공증명

174

담보제공(공탁)증명				
원	고	○	○	○
피	고	○	○	○
위 당사자 사이의 ○○지방법원 20 가합 청구사건에 관한 판결의 가집행의 담보로 20 . . . ○○지방법원 20 년 금 제○○○호로서 금 ○○○원을 공탁하 였음을 증명하여 주시기 바랍니다. 2000. ○. ○. 원 고(신청인) (날인 또는 서명) 위 증명함. 2000. ○. ○. ○○지방법원 법원사무관 ㉠				

민집 23㉠, 민소 502㉡

제1편
제7장
제5절

제5절 담보권의 실행, 담보의 취소, 담보의 변경

법원실무제요 민사소송[I] 제14장 제5절 담보권의 실행, 제6절 담보의 취소, 제7절 담
 보물변경 참조